ADVOCACIA DE GUERRILHA

PLAYBOOK

Providência Cautelar Antecipatória para Emissão de Autorização de Residência

Fundamentos Jurisprudenciais e Minuta de Articulado

PARTE I — ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTO DA VIA CAUTELAR

1. A questão de partida

A questão que este playbook visa responder é a seguinte: pode uma providência cautelar antecipatória ter por objecto a emissão provisória de uma autorização de residência, mesmo que esse seja também o objecto da acção administrativa principal? A resposta que a jurisprudência do Tribunal Central Administrativo Sul firmou, de forma reiterada e coerente, é afirmativa.

A circunstância de o efeito cautelar se aproximar ou coincidir com o efeito pretendido na acção principal não é, por si só, fundamento de inadmissibilidade. O que importa verificar é que a tutela cautelar mantém a sua natureza instrumental e provisória e que o processo principal prossegue para produzir caso julgado material sobre a relação jurídica controvertida.

2. A génese jurisprudencial do entendimento

A linha jurisprudencial relevante construiu-se precisamente a propósito dos casos em que os requerentes pretendiam utilizar o processo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias, previsto no artigo 109.º do CPTA, como via para obter a emissão do título de residência. Em todos esses casos, os tribunais recusaram o meio processual escolhido, mas fazendo-o com um argumento que, simultaneamente, abre e consolida a via cautelar.

O raciocínio do TCA Sul é que a intimação do artigo 109.º do CPTA tem natureza subsidiária e pressupõe que não seja possível ou suficiente o decretamento provisório de uma providência cautelar. A recusa da intimação assenta, precisamente, na afirmação de que a providência cautelar é possível e suficiente para tutelar os direitos invocados. Ao dizer que a intimação não

é o meio adequado porque existe a via cautelar, os tribunais estão a reconhecer, implicitamente mas de forma inequívoca, que a via cautelar comporta esse objecto.

3. Os textos jurisprudenciais determinantes

O acórdão do TCA Sul de 15 de Dezembro de 2016, proferido no Processo n.º 1668/16.1BELSB, constitui o texto de referência desta corrente. Apreciando a recusa de emissão do título de residência, o Tribunal afirmou expressamente:

> *"o recorrente poderá intentar uma acção administrativa, sendo-lhe possível obter a tutela urgente dos direitos que invoca através de um processo cautelar, no qual formule pedido de intimação do recorrido a emitir, provisoriamente, o título de residência"*

Acórdão TCA Sul, Proc. 1668/16.1BELSB, 15.12.2016, Rel. Catarina Jarmela

Esta formulação não é um obiter dictum. É o fundamento principal pelo qual o Tribunal negou provimento ao recurso e manteve a decisão que havia recusado a intimação do artigo 109.º: a protecção pretendida é obtível por via cautelar, razão pela qual o meio urgente definitivo é inadmissível. O mesmo Tribunal, no acórdão de 5 de Julho de 2017, proferido no Processo n.º 532/17.1BELSB, retomou a mesma formulação na íntegra:

> *"o recorrente poderá intentar uma acção administrativa, sendo-lhe possível obter a tutela urgente dos direitos que invoca através de um processo cautelar, no qual formule pedido de intimação do recorrido a emitir, provisoriamente, o título de residência"*

Acórdão TCA Sul, Proc. 532/17.1BELSB, 5.7.2017, Rel. José Correia

O acórdão de 16 de Fevereiro de 2017, proferido no Processo n.º 1753/16.0BELSB, confirma a mesma linha, com remissão para o aresto de Dezembro de 2016, salientando que a ausência de urgência qualificada não determina absolvição da instância mas sim o convite à substituição da petição por requerimento cautelar, nos termos do artigo 110.º-A, n.º 1, do CPTA.

Acórdão TCA Sul, Proc. 1753/16.0BELSB, 16.2.2017, Rel. Helena Canelas

4. O fundamento doutrinário da não-incompatibilidade

A questão da coincidência entre o objecto cautelar e o objecto da acção principal foi directamente endereçada na fundamentação do acórdão de 15 de Dezembro de 2016, com apoio na doutrina de Carla Amado Gomes. O Tribunal citou a posição de que a emissão provisória do

título de residência por via cautelar não constitui situação irreversível, podendo a decisão ser revogada pelo Tribunal ao abrigo do artigo 124.º, n.º 1, do CPTA.

Para fundamentar esta conclusão, o Tribunal convocou ainda o acórdão do próprio TCA Sul de 10 de Novembro de 2011, proferido no Processo n.º 8059/11, que, a propósito da emissão cautelar do cartão de equiparado a jornalista, esclareceu que o decretamento provisório de tal título não põe em causa a provisoriedade que caracteriza os processos cautelares, pois a decisão cautelar pode ser revogada e não produz efeitos de direito irreversíveis.

A lógica subjacente é a seguinte: o que impede a providência cautelar antecipatória não é a coincidência formal entre o efeito cautelar e o efeito da acção principal, mas a irreversibilidade prática do efeito antecipado. Quando o efeito antecipado é reversível, como acontece com a emissão de um título que pode ser revogado ou que caduca com a decisão da acção principal, a tutela cautelar é admissível.

5. Os pressupostos de procedência

A admissibilidade da via cautelar é uma coisa; a procedência do pedido é outra. Para que a providência seja decretada, devem estar preenchidos os pressupostos gerais das providências cautelares, previstos no artigo 120.º do CPTA.

O fumus boni iuris exige que o requerente demonstre a aparência séria do direito que invoca. Nos casos de emissão de autorização de residência, os tribunais têm reconhecido esta aparência quando o requerente demonstra ter preenchido os requisitos legais e que a Administração nada alegou de concreto que obstasse à concessão. O acórdão do TCA Sul de 16 de Fevereiro de 2017 reconheceu que a demonstração documental do preenchimento dos requisitos do artigo 88.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2007, acompanhada do silêncio da Administração quanto a factos impeditivos, configura aparência suficiente do direito.

O periculum in mora exige a demonstração de que a ausência de decisão judicial imediata causará ao requerente prejuízo de difícil reparação. A jurisprudência é exigente neste ponto: não basta a invocação genérica de direitos constitucionais. Exige-se a concretização de situações específicas, como o risco de perda de emprego por imposição de prazo pela entidade patronal, a impossibilidade de acesso a serviços de saúde ou a separação da família, com suporte factual verificável.

A proporcionalidade do decretamento impõe ainda que os prejuízos que o decretamento da providência cause ao requerido não sejam manifestamente superiores aos que se pretendem evitar para o requerente.

6. A limitação do acórdão de 2018

O acórdão do TCA Sul de 5 de Abril de 2018, proferido no Processo n.º 2442/17.3BELSB, introduziu uma limitação que importa conhecer. Nesse aresto, o Tribunal afirmou que não há que fazer o convite previsto no artigo 110.º-A, n.º 1, do CPTA quando o direito de acção principal se encontre já caducado, ao abrigo do artigo 69.º, n.º 1, do CPTA, pois convidar à dedução de uma providência cautelar instrumental de uma acção principal inadmissível seria um acto processual inútil.

Acórdão TCA Sul, Proc. 2442/17.3BELSB, 5.4.2018, Rel. Paulo Pereira Gouveia

Esta limitação aplica-se, por identidade de razão, à própria propositura da providência cautelar autónoma: se a acção principal já caducou, a instrumentalidade cautelar fica comprometida e o pedido será inadmissível. É, portanto, indispensável verificar, antes da propositura da cautelar, se o prazo de propositura da acção principal, em regra, o prazo do artigo 58.º do CPTA para impugnação de actos ou o prazo do artigo 69.º para acções de condenação, se encontra ainda em aberto.

PARTE II — MINUTA DE ARTICULADO

Do Cabimento da Presente Providência Cautelar

I. Da natureza e admissibilidade do meio processual utilizado

1.º

A presente providência cautelar tem por fundamento o disposto nos artigos 112.º e seguintes do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, sendo deduzida em articulação com a acção administrativa principal que pende nos presentes autos e que tem por objecto a condenação da

entidade demandada à prática do acto de concessão de autorização de residência e emissão do correspondente título.

2.º

Reconhece-se que o efeito que ora se pretende obter em via cautelar, a emissão provisória do título de residência, se aproxima, na sua substância, do efeito que a sentença da acção principal virá a produzir. Tal aproximação não constitui, porém, fundamento de inadmissibilidade, conforme resulta de forma inequívoca da jurisprudência do Tribunal Central Administrativo Sul.

3.º

Com efeito, o TCA Sul foi chamado, em múltiplos arestos, a pronunciar-se sobre a via processual adequada para obter, em tempo útil, a emissão de título de residência perante a inércia da Administração. Em todos esses casos, o Tribunal recusou a via da intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias prevista no artigo 109.º do CPTA, não com fundamento na improcedência do direito invocado, mas precisamente porque afirmou existir uma via igualmente eficaz e processualmente adequada: a da providência cautelar antecipatória, deduzida no âmbito de acção administrativa.

4.º

Esta afirmação não constitui um fundamento marginal nos arestos referidos. É, antes, o fundamento central da recusa da intimação, pois o pressuposto do artigo 109.º, n.º 1, do CPTA que o tribunal deu por não verificado foi exactamente a impossibilidade ou insuficiência da tutela cautelar. Ao decidir que a intimação é inadmissível porque a providência cautelar é possível e suficiente, o Tribunal reconheceu, simultaneamente, que a via cautelar comporta este objecto.

II. <u>Os textos jurisprudenciais que fundamentam o presente pedido</u>

5.º

O acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 15 de Dezembro de 2016, proferido no Processo n.º 1668/16.1BELSB, constitui o texto fundador desta linha jurisprudencial.

Apreciando um caso em que o requerente havia utilizado a intimação do artigo 109.º do CPTA para obter a emissão do título de residência, o Tribunal Sul afirmou:

> *"o recorrente poderá intentar uma acção administrativa, sendo-lhe possível obter a tutela urgente dos direitos que invoca através de um processo cautelar, no qual formule pedido de intimação do recorrido a emitir, provisoriamente, o título de residência"*

Acórdão TCA Sul, Proc. 1668/16.1BELSB, 15.12.2016, Rel. Catarina Jarmela

6.º

O mesmo entendimento foi retomado pelo TCA Sul no acórdão de 5 de Julho de 2017, proferido no Processo n.º 532/17.1BELSB, onde o Tribunal manteve a decisão de recusar a intimação com fundamento em que, nos casos de pedido de emissão de título de residência:

> *"não se verifica o pressuposto enunciado sem segundo lugar — impossibilidade ou insuficiência do decretamento provisório de uma providência cautelar no âmbito de uma acção administrativa —, dado que é possível e é suficiente o decretamento de uma providência cautelar no âmbito de uma acção administrativa. Com efeito, o recorrente poderá intentar uma acção administrativa, sendo-lhe possível obter a tutela urgente dos direitos que invoca através de um processo cautelar, no qual formule pedido de intimação do recorrido a emitir, provisoriamente, o título de residência"*

Acórdão TCA Sul, Proc. 532/17.1BELSB, 5.7.2017, Rel. José Correia

7.º

O acórdão do TCA Sul de 16 de Fevereiro de 2017, proferido no Processo n.º 1753/16.0BELSB, acrescentou ainda que a ausência de situação de especial urgência subjacente à necessidade da intimação não determina a absolvição da instância, impondo-se ao tribunal que convide o autor a substituir o pedido para o efeito de requerer a adopção de providência cautelar, nos termos do artigo 110.º-A, n.º 1, do CPTA. Este convite pressupõe, necessariamente, que o objecto da providência cautelar assim obtida seja precisamente o que o autor havia peticionado na intimação, a emissão do título, confirmando a admissibilidade da via ora utilizada.

Acórdão TCA Sul, Proc. 1753/16.0BELSB, 16.2.2017, Rel. Helena Canelas

III. Da não-incompatibilidade entre o objecto cautelar e o objecto da acção principal

8.º

Poder-se-ia objectar que o decretamento provisório da emissão do título de residência esgotaria os efeitos da acção principal, tornando a providência inadmissível por falta de provisoriedade. Esta objecção não procede.

9.º

O TCA Sul enfrentou este argumento directamente no acórdão de 15 de Dezembro de 2016, invocando para o efeito a posição de Carla Amado Gomes e a jurisprudência do próprio Tribunal contida no acórdão de 10 de Novembro de 2011, proferido no Processo n.º 8059/11. Nesse aresto anterior, o Tribunal havia precisado que a emissão a título provisório de um título habilitante, nesse caso, o cartão de equiparado a jornalista, não constitui uma situação irreversível, podendo ser revogada pelo Tribunal ao abrigo do artigo 124.º, n.º 1, do CPTA, e que, portanto, tal decretamento não excede os limites da tutela cautelar.

10.º

A razão de ser desta conclusão é clara na sua lógica: o que a provisoriedade das providências cautelares veda não é a antecipação de efeitos que coincidem com os da sentença principal, mas a antecipação de efeitos que, pela sua natureza, tornem inútil ou impossível a sentença principal ou que produzam efeitos definitivos independentemente desta. Quando a situação criada cautelarmente é revogável, e a emissão provisória de um título de residência o é, pois o tribunal pode revogar a providência e a própria acção principal produzirá o resultado definitivo, o pressuposto da provisoriedade mantém-se intacto.

IV. Da verificação do fumus boni iuris

11.º

Para efeitos do presente pedido cautelar, o fumus boni iuris é demonstrado pela existência de elementos documentais que atestam o preenchimento, pelo requerente, dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da autorização de residência, bem como pela ausência de

qualquer oposição fundamentada da entidade demandada relativamente a factos concretos impeditivos da concessão.

12.º

Neste ponto, importa notar que o TCA Sul, no acórdão de 16 de Fevereiro de 2017, ao debruçar-se sobre a situação de um requerente que havia demonstrado documentalmente o preenchimento dos requisitos do artigo 88.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, reconheceu que tal demonstração, acompanhada do silêncio da Administração quanto a factos impeditivos, era suficiente para concluir que o requerente possuía um direito aparente à concessão. Disse o Tribunal a propósito da entidade demandada: «o R. não alegou nem demonstrou qualquer facto impeditivo do direito do A., sendo ónus seu tal demonstração».

Acórdão TCA Sul, Proc. 1753/16.0BELSB, 16.2.2017, Rel. Helena Canelas

13.º

No caso dos presentes autos, a situação é análoga: o requerente demonstrou o preenchimento dos requisitos legais através dos documentos juntos, pagou as taxas devidas, e a entidade demandada não apresentou, em sede procedimental, qualquer oposição fundamentada em factos concretos que obstem à concessão.

V. <u>Da verificação do periculum in mora</u>

14.º

O periculum in mora é constituído pelo prejuízo concreto e de difícil reparação que resulta, para o requerente, da manutenção, até à sentença da acção principal, da situação de ausência de título que comprove a sua autorização de residência.

15.º

A jurisprudência do TCA Sul tem sido clara quanto à exigência de concretização do periculum. No acórdão de 15 de Dezembro de 2016, o Tribunal afirmou, em termos que balizam a argumentação, que não bastava a invocação genérica de direitos constitucionais, sendo necessária a alegação de factos concretos que demonstrassem a iminência de uma perda

irreversível de faculdades de exercício do direito ou uma situação de carência pessoal ou familiar em que estivesse em causa a imediata e directa sobrevivência pessoal.

16.º

No presente caso, o periculum concretiza-se nas seguintes circunstâncias, que o requerente alega e está em condições de demonstrar: [indicar aqui os factos concretos, pressão da entidade patronal com prazo para apresentação do título, impossibilidade de acesso regular a cuidados de saúde, situação de separação familiar ou outros factos verificáveis que excedam a mera generalidade].

17.º

Estes factos revelam que a manutenção da situação actual até à sentença da acção principal causará ao requerente prejuízos que, pela sua natureza, não serão susceptíveis de reparação adequada pela mera declaração do direito em sede de acção principal.

VI. <u>Conclusão quanto ao cabimento</u>

18.º

Face ao exposto, a presente providência cautelar é admissível, tem suporte na jurisprudência reiterada do Tribunal Central Administrativo Sul, e encontra-se nos pressupostos de procedência previstos no artigo 120.º do CPTA. A via processual utilizada não apenas é legal como é, em rigor, o meio que a jurisprudência indicou como o adequado para a tutela dos direitos do requerente perante a inércia da Administração na emissão da autorização de residência.

REFERÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 15 de Dezembro de 2016, Processo n.º 1668/16.1BELSB, Relator: Catarina Jarmela.

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 16 de Fevereiro de 2017, Processo n.º 1753/16.0BELSB, Relator: Helena Canelas.

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 16 de Fevereiro de 2017, Processo n.º 0108/17, Relator: Alberto Augusto Oliveira.

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 5 de Julho de 2017, Processo n.º 532/17.1BELSB, Relator: José Correia.

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 5 de Abril de 2018, Processo n.º 2442/17.3BELSB, Relator: Paulo Pereira Gouveia.

Acordão de 2017-02-16 (Processo nº 1753/16.0BELSB), de 16 de fevereiro

Emitente: Tribunal Central Administrativo Sul

Tipo: Acordão

Processo: 1753/16.0BELSB

Fonte Direito: DECISÕES JUDICIAIS

Relator: HELENA CANELAS

Descritores: INTIMAÇÃO PARA PROTECÇÃO DE DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS; AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA; INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL

Informação da publicação

Data de Publicação: 2017-02-16

SUMÁRIO

I – O processo de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, previsto no artigo 109.º do CPTA, destina-se a cobrir situações que exigem um especial amparo jurisdicional, por não se mostrar adequada, por impossibilidade ou insuficiência, a proteção jurídica que os demais meios urgentes conferem.II - Só é legítimo a ele recorrer quando esteja em causa a lesão, ou a ameaça de lesão, de um direito, liberdade ou garantia (ou de um direito fundamental de natureza análoga) cuja proteção seja urgente.III - De acordo com o disposto no novo artigo 110.º-A n.º 1 do CPTA, a não verificação de situação de especial urgência subjacente à necessidade da intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias não determina a imediata absolvição da instância, impondo-se ao tribunal que convide o autor a substituir o pedido, para o efeito de requerer a adoção de providência cautelar.

TEXTO

Acordam em conferência na Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal Central Administrativo Sul:

I. RELATÓRIO

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras interpõe o presente recurso jurisdicional da sentença de 06/10/2016 do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa que, no âmbito do presente Processo de Intimação para Defesa de Direitos, Liberdades e Garantias, que contra si foi proposto por IRFAN……., nacional do Paquistão (identificado nos autos), julgou a mesma procedente e intimou a entidade requerida a proceder à prática da decisão de autorização de residência e consequente emissão do título de residência no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de sanção

compulsória.
Formula o recorrente as seguintes conclusões, nos seguintes termos (por nós numeradas):

1. Os processos urgentes devem ser reservados para as situações de verdadeira urgência na obtenção de uma decisão sobre o mérito da causa (que coincidem com aquelas para as quais não é possível ou suficiente a utilização de um processo não urgente);
2. E para aquelas onde exista necessidade de uma protecção acrescida dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;
3. Está em causa a concessão de autorização de residência ao abrigo do art. 88.º n.º 2 da Lei n.º 23/2007, de 4/7, o qual configura um mecanismo excepcional e oficioso;
4. O recorrido não é titular de qualquer direito, liberdade ou garantia posto em crise por um acto administrativo (que ora apenas existe por imposição da douta Sentença);
5. A actuação do recorrente não belisca nenhum direito do recorrido;
6. Ao invés, a Sentença a quo viola transversalmente não só o Principio da legalidade, como também o Princípio da igualdade.
7. Nos termos legais, ao cidadão nacional de país terceiro é exigível, em regra, que cumpra as leis nacionais, designadamente solicitando no país de origem, junto das autoridades consulares portuguesas, o competente visto de residência, com o qual, deve solicitar autorização de residência para exercício de actividade profissional subordinada no nosso país;
8. Só excepcional e oficiosamente, é dada oportunidade de requerer uma autorização de residência sem a posse de visto de residência, apresentando manifestação de interesse para averiguação do preenchimento (ou não) das condições vinculativas/cumulativas para abertura do procedimento administrativo;
9. Foi apresentada manifestação de interesse e efectuadas diligências instrutórias, as quais à data da Sentença não se encontravam cabalmente apreciadas, não podendo assim sem mais, concluir-se pela obrigatoriedade de concessão de autorização de residência;
10. Não foram violados quaisquer dos direitos constitucionais genericamente alegados e carecidos da indispensável concretização ou densificação.
11. Malogradamente o mesmo não ocorre com a controvertida decisão.
12. Pelo que urge trazer a situação existente anteriormente à prolação daquele veredicto, na firme convicção de que só assim será possível repor a justiça, afastando destarte a reprovável violação não só das normas legais habilitantes, mas outrossim, em primeiro plano, dos Princípios constitucionais em causa.
O recorrido contra-alegou pugnando pela manutenção da sentença recorrida.
Remetidos os autos em recurso a este Tribunal, neste notificado nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 146.º e 147.º do CPTA, o Digno Magistrado do Ministério Público emitiu Parecer no sentido da procedência do recurso. Sendo que dele notificadas as partes nenhuma se apresentou a responder.

*

Sem vistos, em face do disposto no artigo 36º nº 1 alínea e) e nº 2 do CPTA, foi o processo

submetido à Conferência para julgamento.

*

II. DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO/DESQUESTÕES A DECIDIR

O objeto do recurso é delimitado pelas conclusões das respetivas alegações, nos termos dos artigos 144º nº 2 e 146º nº 4 do CPTA e dos artigos 5º, 608º nº 2, 635º nºs 4 e 5 e 639º do CPC novo, ex vi dos artigos 1º e 140º do CPTA.

No caso em face dos termos em que foram enunciadas pelo recorrente as conclusões de recurso, vêm colocadas a este Tribunal em recurso, as seguintes questões essenciais, a conhecer pela seguinte ordem:

- a questão de saber se o Tribunal a quo incorreu em erro de julgamento, com errada interpretação do artigo 109º do CPTA, ao julgar improcedente a questão prévia de inadequação do meio processual que foi suscitada pela entidade demandada na sua contestação, considerando assim o Processo de Intimação para Proteção de Direitos, Liberdades e Garantias de que o recorrido lançou mão, meio processual adequado;
- a questão de saber se o Tribunal a quo incorreu em erro de julgamento, quanto à solução jurídica da causa, ao conceder provimento à pretensão do recorrido, intimando a entidade requerida a proceder à prática da decisão de autorização de residência e consequente emissão do título de residência no prazo de 15 dias.

*

III. FUNDAMENTAÇÃO

A – De facto

Nos termos do nº 6 do artigo 663º do CPC novo (aprovado pela Lei nº 41/2013), aqui aplicável ex vi dos artigos 1º e 140º do CPTA, remete-se para a factualidade dada como provada na sentença recorrida.

**

B – De direito

1. Da sentença recorrida

Na sentença recorrida, de 06/10/2016, o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa apreciando a questão prévia de inadequação do meio processual que havia sido suscitada pela entidade demandada na sua contestação, julgou improcedente.

Decisão que assentou no seguinte discurso fundamentador, que se passa a transcrever:

«Alega o R. que o meio processual empregue não é adequado, desde logo, porque o A. “não é titular de qualquer direito à concessão de um título que o habilite a permanecer/residir em Portugal, exigindo-se-lhe para efeito o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 23/2007, de 4/7, e, bem assim, no Decreto Regulamentar nº 84/2007, de 5/11, o que, in casu, não terá acontecido.”

Conclui que “Dado que não se verifica a violação de qualquer direito, liberdade e garantia, nem tão

pouco a necessidade e indispensabilidade da intimação para a sua defesa, pressupostos da utilização deste meio processual (cf. artº 109º nº 1 do CPTA), o que consubstancia a excepção dilatória inominada de inadequação do meio processual."

Vejamos.

Como resulta do probatório, constam do p.a. documentos provando que o A. reúne os requisitos legais previstos no n.º 2 do art.º 88.º da Lei n.º 23/2007 desde 25.9.2015, ou seja, pode ser titular de autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada.

Ora, não tendo esta autorização sido ainda emitida, é manifesto que o A. se mostra privado da possibilidade de beneficiar da aplicação do princípio da Equiparação ou do tratamento nacional, previsto no art.º 15.º n.º 1 da CRP. Alega o R. que "este princípio não é absoluto: o respectivo âmbito de aplicação abrange tão só os cidadãos estrangeiros cuja entrada e permanência tenha sido autorizada em conformidade com o regime previsto nos diplomas supra referidos, em nome dos interesses constitucionalmente tutelados por aqueles – a segurança interna e a ordem pública." Contudo, o R. não concretiza qualquer razão de segurança interna ou qualquer ofensa da ordem pública impeditivas do direito do A..

Ora a factualidade provada revela que a autorização de residência para exercício de actividade profissional poderia ter sido concedida a partir de 2.10.2015.

Assim sendo, é manifesta a urgência na tutela do direito do A., a título principal, pelas razões concretas que invoca, desde logo, a protecção na doença, enquanto trabalhador, além da plenitude de gozo das suas liberdades individuais.

Forçoso é, assim, julgar improcedente a exceção invocada.»

Após o que, debruçando-se dobre o mérito da pretensão, e percorrendo os normativos legais que convocou, deu provimento ao pedido de intimação, pelos seguintes fundamentos, que assim externou, e se passa igualmente a transcrever:

«Começa-se por recordar o texto do artigo 88.º da Lei n.º 23/2007, que se transcreve:

1 - Para além dos requisitos gerais estabelecidos no artigo 77.º, só é concedida autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada a nacionais de Estados terceiros que tenham contrato de trabalho celebrado nos termos da lei e estejam inscritos na segurança social.

2 - Excecionalmente, mediante proposta do diretor nacional do SEF ou por iniciativa do membro do Governo responsável pela área da administração interna, pode ser dispensado o requisito previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 77.º, desde que o cidadão estrangeiro, além das demais condições gerais previstas nessa disposição, preencha as seguintes condições:

a) Possua um contrato de trabalho ou tenha uma relação laboral comprovada por sindicato, por associação com assento no Conselho Consultivo ou pela Autoridade para as Condições de Trabalho;

b) Tenha entrado legalmente em território nacional e aqui permaneça legalmente;

c) Esteja inscrito e tenha a sua situação regularizada perante a segurança social.

3 - A concessão de autorização de residência nos termos dos números anteriores é comunicada pelo SEF, por via eletrónica, ao Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., e nas regiões autónomas aos correspondentes serviços regionais, para efeitos de execução do contingente definido nos termos do artigo 59.º

4 - A concessão de autorização de residência nos termos dos números anteriores é comunicada pelo

SEF, por via eletrónica, à Autoridade para as Condições de Trabalho ou, nas regiões autónomas, à respetiva secretaria regional, de modo que estas entidades possam fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações legais da entidade patronal para com o titular da autorização de residência, bem como à administração fiscal e aos serviços competentes da segurança social.
5 - O titular de uma autorização de residência para exercício de uma atividade profissional subordinada pode exercer uma atividade profissional independente, mediante substituição do título de residência, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo seguinte.

E, bem assim, do art.º 77.º da mesma Lei, que sob a epígrafe, "Condições gerais de concessão de autorização de residência temporária", dispõe o seguinte:

1 - Sem prejuízo das condições especiais aplicáveis, para a concessão da autorização de residência deve o requerente satisfazer os seguintes requisitos cumulativos:
a) Posse de visto de residência válido, concedido para uma das finalidades previstas na presente lei para a concessão de autorização de residência;
b) Inexistência de qualquer facto que, se fosse conhecido pelas autoridades competentes, devesse obstar à concessão do visto;
c) Presença em território português;
d) Posse de meios de subsistência, tal como definidos pela portaria a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 52.º;
e) Alojamento;
f) Inscrição na segurança social, sempre que aplicável;
g) Ausência de condenação por crime que em Portugal seja punível com pena privativa de liberdade de duração superior a um ano;
h) Não se encontrar no período de interdição de entrada em território nacional, subsequente a uma medida de afastamento do País;
i) Ausência de indicação no Sistema de Informação Schengen;
j) Ausência de indicação no Sistema Integrado de Informações do SEF para efeitos de não admissão, nos termos do artigo 33.º.
2 - Sem prejuízo das disposições especiais aplicáveis, pode ser recusada a concessão de autorização de residência por razões de ordem pública, segurança pública ou saúde pública.
3 - A recusa de autorização de residência com fundamento em razões de saúde pública só pode basear-se nas doenças definidas nos instrumentos aplicáveis da Organização Mundial de Saúde ou em outras doenças infeciosas ou parasitárias contagiosas objeto de medidas de proteção em território nacional.
4 - Pode ser exigida aos requerentes de autorização de residência a sujeição a exame
médico, a fim de que seja atestado que não sofrem de nenhuma das doenças mencionadas no número anterior, bem como às medidas médicas adequadas.
5 - Os exames médicos e as medidas a que se refere o número anterior não devem ter caráter sistemático.
6 - Sempre que o requerente seja objeto de interdição de entrada emitida por um Estado parte ou

Estado associado na Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, este deve ser previamente consultado devendo os seus interesses ser tidos em consideração, em conformidade com o artigo 25.º daquela Convenção.

O A. demonstrou possuir todos os requisitos legais exigidos, no momento temporal em que o R. admitiu o uso deste meio excepcional e oficioso, tendo até pago todas as taxas inerentes ao deferimento. Por outro lado, o R. não alegou nem demonstrou qualquer facto impeditivo do direito do A., sendo ónus seu tal demonstração. Assim sendo, a omissão do dever de decidir o pedido do A. viola o princípio da confiança, pois que o A. pediu a autorização de residência em apreço, instruiu o pedido com todos os documentos exigidos, pagou todas as taxas devidas inerentes ao deferimento do pedido e não obteve decisão, decorrido um ano. Neste caso, a discricionariedade encontra-se reduzida a zero, pois a partir do momento em que abriu a possibilidade de legalização, auto vinculou-se a decidir.»

Tendo então concluído com o seguinte segmento decisório:
«Nestes termos, intima-se o R. à prática da decisão de autorização de residência e consequente emissão do título de residência e envio do mesmo ao A. no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de sanção pecuniária compulsória.»

~
2. Da tese do recorrente
2.1 No recurso que a entidade demandada dirige à sentença o recorrente insurge-se primeiramente quanto à decisão que considerou não se verificar a impropriedade do meio processual, imputando-lhe erro de julgamento, com errada interpretação do artigo 109º do CPTA.
Sustenta a tal respeito que o Processo de Intimação para Proteção de Direitos, Liberdades e Garantias deve ser reservado para as situações de verdadeira urgência na obtenção de uma decisão sobre o mérito da causa (que coincidem com aquelas para as quais não é possível ou suficiente a utilização de um processo não urgente) e para aquelas onde exista necessidade de uma proteção acrescida dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos; que este processo constitui um meio processual urgentíssimo e de última ratio, que demanda a invocação de um evento próximo que determine a alteração da situação em termos tais que impossibilite, de forma absoluta e irrepreensível, o exercício dos direitos alegados e que, como tal, exija uma solução célere e definitiva, o que no caso não foi invocado; que assim, contrariamente ao considerado na sentença recorrida, a Intimação para a defesa de direitos, liberdades e garantias claramente não é o meio processual adequado face à natureza dos pedidos deduzidos; alegando, designadamente, que está em causa a concessão de autorização de residência ao abrigo do art. 88.º n.º 2 da Lei n.º 23/ 2007, de 4/7, o qual configura um mecanismo excecional e oficioso não sendo o recorrido titular de qualquer direito, liberdade ou garantia posto em crise por um ato administrativo, que inexiste; que a concessão de autorização de residência não constitui um direito (absoluto) dos nacionais de país terceiro, exigindo a observância de requisitos legai e prefigurando um direito adquirido constituído, que não é inerente à condição humana, ou surge na esfera jurídica de todas as pessoas, mas que

está na disponibilidade do legislador; e que as asserções feitas pelo recorrido na primeira instância, acolhidas na sentença a quo, mencionam apenas "que a situação irregular (...) não lhe traz qualquer tranquilidade, nem sequer para andar em público (...) a todo o tempo, e em qualquer local (na rua, no metro, no seu local de trabalho) pode ser objeto de ações de fiscalizações e pode ser mandado parar pela policia", as quais são, em absoluto, genéricas, não obviando que a situação irregular do recorrido (aparente fonte do seu receio) o sujeita obviamente às respetivas cominações legais.

2.2 E põe igualmente em causa a decisão proferida pelo Tribunal a quo quanto ao mérito da pretensão, sustentando que a mesma viola transversalmente não só o Principio da legalidade, como também o Princípio da igualdade; que nos termos legais, ao cidadão nacional de país terceiro é exigível, em regra, que cumpra as leis nacionais, designadamente solicitando no país de origem, junto das autoridades consulares portuguesas, o competente visto de residência, com o qual, deve solicitar autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada no nosso país; que só excecional e oficiosamente é dada oportunidade de requerer uma autorização de residência sem a posse de visto de residência, apresentando manifestação de interesse para averiguação do preenchimento (ou não) das condições vinculativas/cumulativas para abertura do procedimento administrativo; que no caso foi apresentada manifestação de interesse e efetuadas diligências instrutórias, as quais à data da sentença não se encontravam cabalmente apreciadas, não podendo assim sem mais, concluir-se pela obrigatoriedade de concessão de autorização de residência; que não foram violados quaisquer dos direitos constitucionais genericamente alegados e carecidos da indispensável concretização ou densificação, não ocorrendo o mesmo malogradamente com a decisão recorrida e que assim urge trazer a situação existente anteriormente à prolação daquele veredicto, na firme convicção de que só assim será possível repor a justiça, afastando destarte a reprovável violação não só das normas legais habilitantes, mas outrossim, em primeiro plano, dos Princípios constitucionais em causa.

~

3. Da análise e apreciação do recurso

3.1 A questão de saber se o Tribunal a quo incorreu em erro de julgamento, com errada interpretação do artigo 109º do CPTA, ao julgar improcedente a questão prévia de inadequação do meio processual que foi suscitada pela entidade demandada na sua contestação, considerando assim o Processo de Intimação para Proteção de Direitos, Liberdades e Garantias de que o recorrido lançou mão, meio processual adequado.

3.1.1 A questão aqui trazida em discussão já foi objeto de análise e decisão por este Tribunal Central Administrativo Sul em situação em tudo similar à dos presentes autos, através do acórdão de 15/12/2016, proferido no Proc. nº 1453/16.0BELSB, in, www.dgsi.pt/jtcas, em que interviemos adjuntas.

E não havendo razão para dela dissentirmos, importa recuperar o que ali se foi dito, com propriedade, a tal respeito, e que se passa a citar:

“O meio processual em uso consubstancia um processo principal, em que o tribunal é chamado a apreciar e decidir um litígio em definitivo. É este o sentido do artigo 109.º, n.º 1, do CPTA: “1 - A intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias pode ser requerida quando a célere emissão de uma decisão de mérito que imponha à Administração a adoção de uma conduta positiva

ou negativa se revele indispensável para assegurar o exercício, em tempo útil, de um direito, liberdade ou garantia, por não ser possível ou suficiente, nas circunstâncias do caso, o decretamento provisório de uma providência cautelar, segundo o disposto no artigo 131.º".

A lei estabelece dois pressupostos para utilização deste meio processual; a saber: i) que a emissão urgente de uma decisão de fundo seja indispensável para proteção de um direito, liberdade ou garantia; ii) que não seja possível ou suficiente o decretamento provisório de uma providência cautelar no âmbito de uma ação administrativa, comum ou especial.

Ora, tratando-se de um meio processual urgente e principal, o legislador delimitou-o para um elenco de situações mais ou menos restrito. Ou seja, estão em causa situações que exigem um especial amparo jurisdicional, por não se mostrar adequada, por impossibilidade ou insuficiência, a protecção jurídica que os demais meios urgentes conferem. Como refere Mário Aroso de Almeida, com este meio pretende-se obter, em tempo útil, uma decisão definitiva sobre a questão de fundo, sob pena de haver denegação de justiça (cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, Coimbra, 2003, p. 238). Como refere o Autor citado no seu Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos: "o processo de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias é, assim, instituído como um meio subsidiário de tutela, vocacionado para intervir como uma válvula de segurança do sistema de garantias contenciosas, nas situações – e apenas nessas – em que as outras formas de processo do contencioso administrativo não se revelem aptas a assegurar a protecção efectiva de direitos, liberdades e garantias"(cfr. ob. cit, Coimbra, 2005, p. 538).

Nessa medida, esta intimação veio concretizar o comando normativo contido no n.º 5 do artigo 20.º da CRP, destinando-se, em primeira linha, a assegurar a defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais. Mas ainda que se entenda que o artigo 109.º do CPTA ampliou o seu alcance para além da proteção dos direitos pessoais, não deixa de reconduzir-se sempre ao conjunto dos direitos, liberdades e garantias tipificados no Título II da Constituição e, no limite, aos direitos fundamentais de natureza análoga àqueles. Como salienta Vieira de Andrade, "esta proteção acrescida justifica-se, na sua substância, pela especial ligação destes direitos à dignidade da pessoa humana e, na sua oportunidade, pela consciência do risco acrescido da respectiva lesão (cfr. A Justiça Administrativa (Lições), 7.ª ed., Coimbra, 2005, p. 261; na jurisprudência, o acórdão do STA 6.12.2006, proc. n.º 885/06).

Em suma, o meio processual previsto no artigo 109.º do CPTA tem por escopo garantir uma tutela jurisdicional efetiva e célere quando estão em causa direitos, liberdades e garantias fundamentais, de natureza pessoal, ou de direitos de natureza análoga, na medida em que o regime dos direitos liberdades e garantias também se aplica aos direitos fundamentais de natureza análoga, como decorre do artigo 17.º da CRP, e justifica-se quando seja necessária a célere emissão de uma decisão de mérito que imponha à Administração a adopção de uma conduta positiva ou negativa que se revele indispensável para assegurar o exercício, em tempo útil, desse direito, liberdade ou garantia, ou direito de natureza análoga, por não ser possível ou suficiente, nas circunstâncias do caso, o decretamento provisório de uma providência cautelar (cfr. o recentíssimo ac. deste TCAS de 16.04.2015, proc. n.º 12003/15).

No caso em apreço, o ponto da discussão não está na qualificação do direito invocado como direito fundamental – o que tendencialmente se aceita - está na sim na existência de uma situação de

urgência, sua exigência e respetiva qualificação adjetiva. É essa, para nós, a questão essencial a dirimir.

Na verdade, aceitando embora que foi concretizada na p.i., e reconhecida na decisão recorrida, a existência de uma situação jurídica que colide com um direito, liberdade e garantia de natureza pessoal; importava também a mesma concretização quanto ao requisito da ocorrência de uma situação, no caso concreto, de grave ameaça ou violação do direito, liberdade e garantia em causa, que só pudesse – possa – ser reparada através do processo urgente de intimação (cfr. Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Cadilha, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 3.ª ed., Coimbra, 2010, p. 723). Como ensinam aqueles Autores: "Não releva, por isso, a mera invocação genérica de um direito, liberdade ou garantia que tenha assento constitucional; impõe-se a descrição de uma situação factual de ofensa ou preterição do direito fundamental que possa justificar, à partida, ao menos numa análise perfunctória de aparência do direito, que o tribunal venha a condenar a Administração (através de um processo célere e expedito) a adotar uma conduta (positiva ou negativa) que permita assegurar o exercício desse direito (idem).

De resto o STA decidiu já no ac. de 30.10.2008, proc. no 878/08 que: "O processo de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias é um processo principal e não de um processo cautelar a que só é legítimo recorrer quando esteja em causa a lesão, ou a ameaça de lesão, de um direito, liberdade ou garantia cuja proteção seja urgente e que esta não seja possível ou não seja suficiente através da propositura de uma ação administrativa especial associada a um pedido de decretamento da correspondente providência cautelar" [sublinhado e carregado nosso]. Tal como aí se disse em posição que importa evidenciar: "(…) sem a urgência e sem a indispensabilidade desta decisão, o meio mais adequado para os referidos efeitos será a propositura de uma ação administrativa, comum ou especial, visto ela ser o meio normal de defesa contra os atos administrativos ilegais".

Ou seja, só quando, no caso concreto, se verifique que a utilização das vias não urgentes de tutela judiciária não se mostra possível ou suficiente para assegurar o exercício, em tempo útil, do direito, liberdade ou garantia invocado é que deve entrar em cena o processo de intimação.

Como salienta Vieira de Andrade a propósito do requisito da parte final do n.º 1 do artigo 109.º do CPTA (cfr. A Justiça Administrativa (Lições), 7.ª ed., Coimbra, 2005, p. 263): "em rigor, a expressão legal quer mostrar o carácter excecional da intimação, confirmando a remissão para a ação normal (não urgente) daqueles casos em que, estando embora em causa o exercício de um direito, liberdade e garantia, a decisão de fundo não seja urgente – pois que eventuais perigos de lesão, mesmo que de lesões imediatas e irreversíveis, podem ser resolvidos nesses processos normais através de providências cautelares".

Neste capítulo, o ora Recorrido limitou-se a alegar generalidades, nada de concreto vindo porém alegado que permita sustentar uma especial urgência na tomada de decisão judicial. Aliás, a sentença recorrida, a este respeito, apenas deu como provado que: "4- A falta de decisão sobre o pedido do A. e seus familiares causa-lhes prejuízos." Nada mais ficou nesta sede demonstrado.

Donde, não deu satisfação ao ónus alegatório que lhe estava cometido, nem muito menos provou o ora Recorrido a indispensabilidade do recurso a este meio processual.

O A. não se pode limitar a alegar a dificuldade ou mesmo impossibilidade de exercer o direito, deve provar que, sob pena de perda irreversível de faculdades de exercício daquele direito, a intimação

visa garantir esse exercício em tempo útil, evidenciando uma necessidade de tomada de uma decisão urgente. Competia-lhe demonstrar, por via de alegação devidamente substanciada/concretizada as razões que impunham uma decisão célere e que a condenação na prática do acto devida era, no caso concreto, insuficiente. O que não é feito.

Por outro lado, necessário é não perder de vista que a satisfação da pretensão do ora Recorrido não se apresenta, contrariamente ao que implicitamente vem sustentado na sentença, como automática, inserindo-se num procedimento administrativo complexo.

Assim, de modo a justificar a efetiva necessidade da tutela judicial usada para ver assegurado o seu direito, cabia ao ora Recorrente demonstrar que a sua situação carecia de proteção imediata, incompatível com o decurso do prazo procedimental necessário à instrução e decisão do pedido formulado, e por não ser possível em tempo útil o recurso a um outro meio processual. O que não foi feito, reitera-se, nem a sentença o reconhece efetivamente.

Pelo que, em síntese, não vindo demonstrada a apontada imprescindibilidade, terá que concluir-se que não pode dar-se por verificado que a situação em presença reivindique uma urgência tal que seja merecedora de uma tutela que imponha a necessidade da célere emissão de uma decisão de mérito e que o art. 109.º, n.º 1, do CPTA exige. O processo de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, como já se disse anteriormente, não se basta com a circunstância de a tutela do direito fundamental exigir a prática de um ato administrativo ilegalmente recusado ou omitido, pois que terá que ser preenchido, para além de outros, o pressuposto da urgência de que depende a sua utilização.

Neste particular, salientamos as palavras de Mário Aroso de Almeida e Carlos Cadilha (ob. cit. p. 726): “Com efeito, importa ter presente que o normal e desejável é que os processos se desenrolem nos moldes considerados mais adequados ao cabal esclarecimento das questões, o que exige tempo, o tempo necessário à produção da prova e ao exercício do contraditório entre as partes. Não é, por isso, aconselhável abusar dos processos urgentes, em que a celeridade é necessariamente obtida através do sacrifício, em maior ou menor grau, de outros valores, que, quando ponderosas razões de urgência não o exijam, não devem ser postergados”.

E como já se concluiu neste TCAS em situações em que estava também em causa a discussão do pressuposto da urgência na tomada de uma decisão de mérito, a utilização da intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias só é admissível quando a emissão urgente de uma decisão de fundo do processo seja indispensável para a proteção de um direito, liberdade ou garantia, por não ser possível em tempo útil o recurso a um outro meio processual. Situação que os autos não permitem revelar.

Assim, há que aplicar a doutrina acolhida no acórdão deste TCAS de 27.05.2010, proc. n.º 6231/10. No citado aresto exarou-se, ao que aqui importa, o seguinte discurso fundamentador:

“Como escreve Isabel Celeste M. Fonseca (in “Dos Novos Processos Urgentes no Contencioso Administrativo”, 2004, pág. 77), «a intimação será absolutamente necessária quando não puder ser dispensada, ou seja quando, para proteger direitos fundamentais, a intensidade da necessidade de proteção imediata impeça, por não ser possível em tempo útil, o recurso a um outro meio processual (por exemplo a ação administrativa comum) que seria o meio adequado ou o meio próprio para resolver definitivamente a questão existente».

Assim, a utilização deste meio processual só é admissível "quando a emissão urgente de uma decisão de fundo do processo seja indispensável para proteção de um direito, liberdade ou garantia e não seja possível ou suficiente o decretamento provisório de uma providência cautelar (art. 109º.), obviamente no âmbito de uma ação administrativa normal, seja comum ou especial" (cfr. J.C. Vieira de Andrade, ob. cit., pág. 259).(…)
A falta do referido pressuposto de admissibilidade da intimação consubstancia, na nossa perspetiva, uma exceção dilatória inominada de inadequação do meio processual (cfr. Acórdão deste Tribunal de 16/2/2005, de que foi relator o mesmo dos presentes autos) que tem como consequência a absolvição da instância do ora recorrido."
De igual modo, em situação similar à dos autos, se concluiu no ac. deste TCAS de 6.02.2014, proc. n.º 10704/13:
"Temos, apenas, de resolver a questão de qual o meio processual adequado para apreciar o litígio descrito na p.i.(…)
Está, pois, em causa, saber se é possível ou suficiente, nas circunstâncias do caso concreto invocado (como expressamente exige o artigo 109º CPTA), (i) o decretamento provisório de uma providência cautelar segundo o disposto no artigo 131.º do CPTA e (ii) uma ação administrativa normal. Como se sabe, a figura do artigo 109º CPTA serve apenas para as situações em que está invocada na p.i. uma grave ameaça concreta de violação de concretos direitos fundamentais determinados e determináveis, sem que a tutela jusadministrativa normal seja possível ou suficiente para tutelar o direito invocado.(…)
Note-se, pois, que na p.i. não se invoca sequer a existência de um indeferimento da emissão do visto ou a recusa em decidir.
Ora, da matéria fáctica concreta invocada na p.i., constante do probatório, e mesmo que houvesse um indeferimento, não se descortina aqui a situação de urgência final pressuposta no artigo 109º do CPTA: o A. sempre poderia (i) interpor uma acção administrativa a pedir a condenação na emissão do visto e (ii) pedir uma providência cautelar imediata (artigo 131º CPTA) ou não imediata (artigos 112º a 120º CPTA) de teor antecipatório.
Ao contrário do referido no Ac. TCAS no Pr. Nº 07694/11, tal não retiraria a natureza provisória da providência cautelar cit.; esta natureza significa que a decisão cautelar não pode ter efeitos de direito irreversíveis. Ora, aqui o eventual visto provisório obtido em processo cautelar sempre poderá ser revogado, com as legais consequências".»

3.1.2 Tal como ali, também na situação presente a alegação do requerente na Intimação nada de concreto permite sustentar a verificação de uma situação justificadora do uso, que fez, do meio processual de Intimação para Proteção de Direitos, Liberdades e Garantias, previsto no artigo 109º do CPTA.
Assistindo, pois, neste aspeto razão ao recorrente, não podendo assim manter-se a sentença recorrida, por erro de julgamento, devendo ser revogada.
O que se decide.
~
3.1.3 Todavia, e como também já se entendeu no citado acórdão de 15/12/2016, Proc. nº

1453/16.0BELSB, deste TCA Sul, tal não implica que deva a entidade requerida, ora recorrente, ser absolvida da instância em face do disposto no nº 1 do artigo 110º-A do CPTA (introduzido pelo DL. nº 214-G/2015, de 2 de Outubro), aqui temporalmente aplicável, de acordo com o qual "…quando verifique que as circunstâncias do caso não são de molde a justificar o decretamento de uma intimação, por se bastarem com a adoção de uma providência cautelar, o juiz, no despacho liminar, fixa prazo para o autor substituir a petição, para o efeito de requerer a adoção de providência cautelar, seguindo-se, se a petição for substituída, os termos do processo cautelar".
Impondo-se, portanto, que seja assegurado aquele normativo.
Pelo que, procedendo o recurso com revogação da decisão do Tribunal a quo considerou o Processo de Intimação para Proteção de Direitos, Liberdades e Garantias de que o recorrido lançou mão, meio processual adequado, devem os autos baixar ao Tribunal a quo a fim de ser dado cumprimento ao disposto no artigo 110º-A nº 1, do CPTA, para prolação do competente despacho, em conformidade com aquele normativo.
O que se decide.
~
3.2 Em face do supra decidido, fica prejudicado o conhecimento da segunda questão trazida em recurso.

*
IV. DECISÃO
Nestes termos, acordam em conferência os juízes da Secção de Contencioso Administrativo deste Tribunal em conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida, e ordenando a baixa dos autos ao Tribunal a quo a fim de ser proferido despacho nos termos e para efeitos do disposto no artigo 110º-A nº 1 do CPTA.
~
Sem custas.

*
Notifique.
D.N.

Lisboa, 16 de Fevereiro de 2017

_____

Maria Helena Barbosa Ferreira Canelas (relatora)

_____

Maria Cristina Gallego dos Santos

_____

Catarina de Moura Ferreira Ribeiro Gonçalves Jarmela Declaração de voto:

Voto a decisão de revogação da sentença recorrida, mas não concordo que seja ordenada a baixa dos autos ao tribunal a quo para prolação de despacho nos termos e para os efeitos do disposto no

art. 110º n.º 1-A, do CPTA, conforme se passa a explicitar.

A questão para a qual é solicitada tutela não pode ser resolvida através do processo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias, visto que não é invocada qualquer situação concreta de urgência a exigir uma decisão de fundo no âmbito desse processo, ou seja, tem de ser revogada a sentença recorrida, e deveria ser julgada procedente a excepção de impropriedade do meio processual utilizado e, em consequência, absolvido o réu, ora recorrente, da instância.

Com efeito, inexistindo qualquer situação concreta de urgência inexiste fundamento para o decretamento de uma providência cautelar e, portanto, para a prolação de despacho ao abrigo do art. 110º-A n.º 1, do CPTA, pois, face ao alegado na petição inicial e para tutela dos interesses aí invocados, é suficiente e adequado o meio processual "normal", ou seja, a acção administrativa, sem prejuízo de, logo que surja alguma situação urgente carecida de tutela, poder ser intentado, por apenso, um processo cautelar.

Em conclusão, o art. 110º-A n.º 1, do CPTA, só deve ser utilizado quando se constate a existência de uma situação de urgência [pressuposto que in casu não se verifica], mas em que é possível e suficiente o decretamento de uma providência cautelar no âmbito de uma acção administrativa.

Acordão de 2017-07-05 (Processo nº 532/17.1BELSB), de 5 de julho

Emitente: Tribunal Central Administrativo Sul

Tipo: Acordão

Processo: 532/17.1BELSB

Fonte Direito: DECISÕES JUDICIAIS

Relator: JOSÉ CORREIA

Descritores: INTIMAÇÃO PARA PROTECÇÃO DE DIREITOS LIBERDADES E GARANTIAS ; REQUISITOS DE QUE DEPENDE A UTILIZAÇÃO NO CASO DE PEDIDO DE CONCESSÃO OU PRORROGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Informação da publicação

Data de Publicação: 2017-07-05

SUMÁRIO

I)- Os requisitos de que depende a utilização da intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias reconduzem-se aos seguintes critérios práticos (i) o juiz do processo (não urgente) principal não chegaria a tempo de ditar a justiça para a situação, isto é, para protecção de um direito, liberdade ou garantia e (ii) o juiz da causa cautelar se ditasse a justiça para a situação teria antecipado ilegitimamente a decisão de mérito.II) - Não se verifica o pressuposto enunciado sem segundo lugar - impossibilidade ou insuficiência do decretamento provisório de uma providência cautelar no âmbito de uma acção administrativa -, dado que é possível e é suficiente o decretamento de uma providência cautelar no âmbito de uma acção administrativa.III) - Com efeito, o recorrente poderá intentar uma acção administrativa, sendo-lhe possível obter a tutela urgente dos direitos que invoca através de um processo cautelar, no qual formule pedido de intimação do recorrido a emitir, provisoriamente, o título de residência.IV) – No caso concreto, a própria Autora alegou que quando formulou o pedido de concessão de autorização de residência no passado dia 29/09/2015, junto ao Posto de Atendimento de Alverca do SEF (PDA ALVERCA), por este Posto de Atendimento foi autorizada a prorrogação de permanência, nos termos do n.°1, do artigo 71.° e do n°2, do artigo 72.°, ambos da Lei 23/2007, de 4 de Julho.V) - Decorre do disposto no artigo 71.°, n°1 da referida Lei n°23/2007 que "Aos cidadãos estrangeiros admitidos em território nacional nos termos da presente lei que desejem permanecer no País por período de tempo superior ao inicialmente autorizado pode ser prorrogada a permanência".V) – E "A prorrogação de permanência pode ser concedida: (...) Até 90 dias, prorrogáveis por um igual período, se o interessado for titular de um visto de curta duração ou tiver sido admitido no País sem exigência de visto"' — cfr. alínea d), do n.°1 do artigo 72.° da Lei n° 23/2007.VI) -Por força do disposto n° 2, do artigo 72.° da referida Lei "A prorrogação de

permanência pode ser concedida, (...), na pendência de pedido de autorização de residência, bem como em casos devidamente fundamentados", sendo que "A prorrogação de permanência concedida aos cidadãos admitidos no País sem exigência de visto e aos titulares de visto de curta duração é limitada a Portugal sempre que a estada exceda 90 dias por semestre, contados desde a data da primeira passagem das fronteiras externas."- cfr. n.° 4 do referido artigo 72.°.VII) -Num tal desiderato a Autora está autorizada a permanecer em Portugal na pendência do pedido de autorização de residência temporária, e, no que tange à necessidade de se deslocar ao Nepal, nada de concreto foi alegado que nos permita concluir que não o poderá fazer mediante pedido devidamente fundamentado que dirija à ER e que em caso de recusa não possa ser acautelado pela via cautelar.VII) – Por isso que o da Autora não tem de considerar-se um caso de “especial urgência” dos previstos no artº 111º do CPTA visto que a petição não permite reconhecer a possibilidade de lesão iminente e irreversível dos direitos, liberdades e garantias invocados.VIII) - É, pois, inelutável que se verifica a excepção dilatória de falta de idoneidade do meio processual, o que invalida a instância já que, tendo o Mº Juiz apreciado as questões que prioritariamente se impunham e se ligavam a pressupostos processuais cuja verificação impedia o conhecimento de quaisquer outras questões.IX) - Uma vez que o Tribunal a quo conheceu de uma excepção dilatória, consistente na falta de idoneidade do meio processual utilizado, isso impõe a prejudicialidade do conhecimento das restantes questões não cabendo conhecer da falta/errada/insuficiente fundamentação de facto, pois, tendo em conta que o conhecimento da excepção dilatória prejudica o conhecimento dos restantes pedidos, nada mais se logrou provar com relevância para a decisão da arguida excepção de falta de idoneidade do meio processual.X) - Significa que em via da procedência da ajuizada excepção não poderia, nem deveria, o Tribunal a quo conhecer dos demais factos ou reconhecer o défice instrutório da sentença, não merecendo a conduta do julgador qualquer censura também nesse plano.XI) – Tanto assim que, tendo a Autora sido convidada a substituir a petição inicial, com o fundamento que a situação em causa nos presentes autos não é de molde a justificar o decretamento de uma intimação, em virtude da factualidade alegada não permitir concluir que estamos perante uma situação em que seja necessária a "célere emissão de uma decisão de mérito", "por não ser possível ou suficiente, (...) o decretamento de uma providência cautelar, segundo o disposto no artigo 131.°", do CPTA, ao invés, é possível e suficiente o decretamento de uma providência cautelar para acautelar a situação da Autora, enquanto não for decidida a acção principal (acção administrativa) e não tendo a Autora acedido ao convite, vindo alegar factos que em nada alteram a situação, como se referiu, impõe-se indeferir liminarmente a petição inicial - cfr. artigos 109.°, n.°1 e 110.°- A, n.°1 do CPTA.

TEXTO

ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, NA 1ª SECÇÃO DO 2º JUÍZO DO TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL

I- RELATÓRIO

ROJYNA ……., dizendo-se inconformada com a sentença do T.A.F. de Lisboa que, no processo de intimação para a protecção de direitos, liberdades e garantias que intentou contra o Sr. Director

do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, julgou verificada a excepção da inidoneidade do meio processual e, em consequência, absolveu o requerido da instância, vêm dela recorrer para este Tribunal, formulando, na respectiva alegação, as seguintes conclusões:

“A — O presente meio processual é o mais adequado,

B- A Autora não revê a sua família M quatro (4) anos.

C- Tem a irmã doente no Nepal e gostaria de casar.

D- O Juiz do processo não urgente principal não chegaria a tempo de ditar Justiça para o caso em concreto.

E- De acordo cora Jorge Miranda e Rui Medeiros há uma reciprocidade ou igualdade no gozo de direitos previstos no art. 44° da Constituição da República Portuguesa entre cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros.

F- O decretamento de uma providência cautelar ira violar a discricionariedade que o Ministério da Administração pública tem em exclusivo quanto a decisões e concessão de residências legais ao abrigo do art. 88º/2 da lei 23/2007.

G- O decretamento de uma providência cautelar viola o princípio da separação de poderes.

H- Não tendo sido a autorização de residência para o exercício de actividade profissional subordinada ainda emitida, o Recorrente mostra-se privado da possibilidade de beneficiar da aplicação do princípio da Equiparação ou do tratamento nacional, previsto no artigo IS", n." l, da Constituição da República Portuguesa.

I- A Autora vive atualmente com MEDO e resignada: Medo que não possa trocar de trabalho e que continue a ser explorada, medo de ser alvo de um processo de expulsão e ser deportado para o Nepal, medo de nunca mais rever ou perder a sua família, medo que não aguente a pressão a que está atualmente sujeita. Peio que Urge intimar o Réu a emitir o cartão de residência para não prolongar este autêntica "agonia", este autêntico "pesadelo" em que o Autor vive,

J — Mais que uma questão legal, configura-se uma questão MORAL: o Estado Português e o Réu (porque recebe 50% destas receitas), NÃO PODEM exigir e receber taxas de centenas de cidadãos, a título de emissão e envio dos seus títulos de residência (bem. como assim, a totalidade das taxas a título de deferimento dos seus pedidos); taxas essas de valor superior a um salário mínimo nacional; reter essas quantias por meses e até anos sem qualquer justificação, e, posteriormente, vir negar a emissão dos mesmos.

L - E, que dizer das expectativas geradas pelo Réu nos requerentes era geral; e, no Recorrente em particular, mediante o pagamento da totalidade das taxas de taxas/emolumentos devidos pela análise e deferimento dos seus pedidos; e do artifício gerado pela recolha de fotos, impressões digitais e assinaturas?

M — Considerando os limites internos inerentes ao poder discricionário, temos que, no caso sub judice a Administração; o Réu, não se revelou nem correcto, nem honesto, nem justo, nem tão pouco bom.

N— O Réu violou, em especial, os princípios da decisão (artigo 13° :do CP A); da eficiência (artigo 5° do CPA); da celeridade (artigo 59° do CPA); da confiança, e da boa administração.

O — O nº 1 do artigo 82°, da Lei 23/2007, estipula que "o pedido de concessão de autorização de residência deve ser decidido ao prazo de 60 dias.".

P — O Réu nada decidiu nesse prazo, nem tão pouco nos dez meses subsequentes; pelo que omitia claramente o seu dever de decisão consagrado ao artigo 52°, n. °1, in fine, a da Constituição, e no artigo 13° do CPA sob a epígrafe "Princípio da Decisão".

Q — Com essa omissão, o Réu violou ainda o princípio da confiança, porque, o Recorrente requereu a autorização de residência em apreço, instruiu o pedido com todos os documentos exigidos, pagou todas as taxas devidas inerentes ao seu pedido e não obteve decisão, decorridos dez meses.

R - Ademais; para além do Recorrente ter demonstrado possuir — naquele momento temporal — todos os requisitos legais exigidos, também é inquestionável que e o Réu admitiu — na mesma data — o uso do meio excepcional e oficioso constante do n.° 2 do artigo 88, da Lei 23/2007,

S — Ou seja, o Réu auto vinculou-se a decidir. E, não decidiu.

T - Não procede a alegação que a discricionariedade que cabia ao Réu ao abrigo do disposto no n.° 2, do artigo 88°, da Lei 23/2007, não está subordinada a prazos, ou está subtraída à observação e cumprimento dos princípios constitucionais da actividade administrativa.

U. — Todo o cidadão é, perante a Administração, um sujeito jurídico de pleno direito, que, numa relação jurídica procedimental tem direito a uma decisão e NUNCA a uma "discricionariedade do silêncio", ou ao "silêncio incumprimento"; que corresponde, afinal, à violação do dever de decidir.

V — Mesmo no caso das autorizações de residência emitidas as abrigo do chamado "regime excepcional' (para os cidadãos que são preencham os requisitos dos restantes tipos de autorização de residência), o SEF está adstrito a agir em conformidade com os princípios constitucionais da actividade administrativa, ou seja, os princípios da prossecução do interesse público, do respeito pelos direitos e interesses dos cidadãos, da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé (cfr. artigo 266° da Constituição).

X — Citando António Francisco de Sousa: "não há discricionariedade sem limites", sendo que "a discricionariedade administrativa é sempre limitada pela lei e pelo Direito" (in "Direito Administrativo em Geral, 4a edição, Porto: FDIIP, 2001, págs. 358 e 298),

Z — A discricionariedade administrativa encontra-se limitada tanto pelas imposições do ordenamento jurídico (limites externos), como pelas exigências do bem comum, da ética administrativa, da boa administração e de todos os princípios que regem a Administração Pública (limites internos); limites que no caso subjudice não foram observados.

AÃ — Se, como afirma Marcelo Caetano "discricionário significa livre dentro dos limites permitidos pela realização de certo fim visado pela lei (in "Princípios Fundamentais do Direito Administrativo", Coimbra: Almedina, a 1996, pág. 129), temos então que, em termos temporais, muito depressa o Réu entrou no domínio da arbitrariedade.

BB-- A lei especial - artigo 82°, nº I, da Lei 23/2007, de 4 de Julho - determina o prazo de 60 dias para a decisão de concessão de autorização de residência. E, a Lei Geral - artigo 86°,nº1I, do (novo) CPA — fixa o prazo de 10 dias.

CC- Este escritório tem Jurisprudência pacífica, unânime, firmada no STA em matéria da Idoneidade do presente Meio processual e na área de Imigração.

TERMOS EM QUE SE CONCLUI NO SENTIDO DE E COM O MUI DOUTO PROVIMENTO DE VOSSAS EXAS:

A) SER REVOGADA A SENTENÇA DO DOUTO TRIBUNAL A QUO.

B) SER CONSIDERADO PROCEDENTE O RECURSO.
C) SEJA CONFIRMADO COMO LIMITE TEMPORAL INSTRUTÓRIO OU DECISÓRIO PARA A CONCESSÃO DE RESIDÊNCIA POR VIA DO ARTIGO 82° N.°1 DA LEI 23/2007 O PRAZO MÁXIMO DE SESSENTA DIAS.
D) OU O PRAZO DE DEZ DIAS POR FOEÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 86°, N.1, DO CPA.

E) DEVE O SER INTIMADO A EMITIR O TÍTULO DE RESIDÊNCIA RELATIVO AO RECORRENTE DE FORMA URGENTE E DEFINITIVA.
f) NO MAIS DEVE SER DECLARADA COMO PROCEDENTE E PROVADA A INTIMAÇÃO,
ASSIM SE FARÁ JUSTIÇA!"

Contra-alegou o SEF, concluindo nos termos do seguinte quadro conclusivo:

"No que à presente intimação concerne, damos por assente que:
-Os processos urgentes devem ser reservados para as situações de verdadeira urgência na obtenção de uma decisão sobre o mérito da causa (que coincidem com aquelas para as quais não é possível ou suficiente a utilização de um processo não urgente);
-E para aquelas onde exista necessidade de uma protecção acrescida dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;
-Está em causa a concessão de autorização de residência ao abrigo do art. 88º n.º 2 da Lei n.º 23/2007, de 4/7, o qual configura um mecanismo excepcional e oficioso;
-Não se denota a violação de qualquer direito da ora requerente, que não é possuidora de qualquer direito "à legalização";
-Pelo contrário, ao cidadão nacional de país terceiro é exigível, em regra, que cumpra as leis nacionais, designadamente solicitando no país de origem, junto das autoridades consulares portuguesas, o competente visto de residência, com o qual, deve solicitar autorização de residência para exercício de actividade profissional subordinada no nosso país;
-Só excepcional e oficiosamente é dada oportunidade de requerer uma autorização de residência sem a posse de visto de residência, apresentando manifestação de interesse para averiguação do preenchimento (ou não) das condições vinculativas/cumulativas para abertura do procedimento administrativo;
-Foi apresentada manifestação de interesse e efectuadas diligências instrutórias, as quais não se repercutem na obrigatoriedade de abertura do procedimento nem, consequentemente, na obrigatoriedade de concessão de autorização de residência;
-Não foram violados quaisquer dos direitos constitucionais genericamente alegados e (parecidos da indispensável concretização ou densificação.
Nestes termos e nos mais de Direito deve a presente resposta ser admitida e em consequência ser julgado improcedente o pedido formulado, pela verificação da excepção dilatória inominada de inadequação do meio processual, ou à cautela, por não se verificarem os requisitos previstos no n.º1 do art. 109º do CPTA."

O Ministério Público, notificado nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 146.º do CPTA, pronunciou-se no sentido da improcedência do recurso, sufragando inteiramente a tese consagrada na sentença.
Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
*
2.- DA FUNDAMENTAÇÃO

Em termos fácticos, na decisão recorrida e com interesse para a decisão, foram tidas em consideração as seguintes realidades e ocorrências:
-A Recorrente instaurou Processo de Intimação para Protecção de Direitos, Liberdades e Garantias contra o Ministério da Administração Interna/Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no qual peticionou que a Entidade Demandada seja intimada a emitir o título de residência da Recorrente, conforme consta do petitório.
-A Autora defendeu desde logo, em sede de petição inicial, que o caso sub iudice não é susceptível de uma decisão provisória, ou seja, de uma decisão cautelar para o que alegou ter concluído com sucesso o seu pedido de concessão de autorização de residência no passado dia 29/09/2015, junto ao Posto de Atendimento de Alverca do SEF.
-Na mesma data, pelo Posto de Atendimento do SEF de Alverca foi autorizada a prorrogação de permanência, nos termos do n.°1, do artigo 71.° e do n° 2, do artigo 72.°, ambos da Lei 23/2007, de 4 de Julho.
-E no mesmo dia foi elaborada proposta de concessão de autorização de residência ao abrigo do regime excepcional previsto no n° 2, do artigo 88.° da Lei n° 23/2007.
-Referiu que está privada da possibilidade de beneficiar da aplicação do Princípio da Equiparação, ou do tratamento nacional, previsto no artigo 15.°, n.°1, da CRP, permanece ainda hoje em situação irregular em território nacional; o que não lhe traz qualquer tranquilidade; nem sequer para andar em público. Pois, a todo o tempo, e em qualquer local (na rua, no metro, no seu local de trabalho), pode ser objecto de acções de fiscalizações, e pode ser mandado parar pela polícia (em que se inclui o próprio SEF), pelo que, está em causa o seu direito à liberdade e à segurança.
-Que sofre também enorme pressão por parte da entidade patronal que lhe faz saber diariamente que quer provas que concluiu o seu processo de regularização em território nacional; sob pena de ser despedido, pelo que está em causa o seu direito ao trabalho.
-Referiu, também, que apenas tem acesso ao sistema de saúde se pagar a integralidade das taxas; seja qual for a circunstância, não obstante descontar mensalmente e desde Janeiro de 2016, a favor da Segurança Social e pagar impostos em território Português, pelo que está em causa o seu direito à saúde e acesso à saúde.
-Mais referiu que sem ver regularizada a sua situação em território nacional, não pode visitar/estar com a sua família no seu País de Origem, nem pode pedir o seu reagrupamento familiar, pelo que, está em causa o seu direito à família. E que necessita de se deslocar ao Nepal para acompanhar uma irmã na doença e para casar.
-A Autora foi convidada a substituir a petição inicial, com o fundamento em que a situação em causa nos presentes autos não é de molde a justificar o decretamento de uma intimação, em virtude de a

factualidade por si alegada não permitir concluir que se esteja perante uma situação em que seja necessária a "célere emissão de uma decisão de mérito", "por ser possível ou suficiente, o decretamento de uma providência cautelar, segundo o disposto no artigo 131", do CPTA pois que, ao invés, é possível e suficiente o decretamento de uma providência cautelar para acautelar a situação da Autora, enquanto não for decidida a acção principal (acção administrativa).
-Neste sentido, conferir o despacho judicial datado de 9 de Março de 2017, constante de fls. 17 e aqui dado por inteiramente reproduzido quanto ao seu teor.
-A Autora, ora Recorrente, nesta sequência, veio dizer que existem factos e informação supervenientes que podem permitir o uso do presente meio processual, concretamente e a saber:
-Tem uma irmã no Nepal de nome ……, que está doente, da qual é muito próxima e faz questão de estar com a mesma neste momento muito difícil da sua vida o mais depressa possível;
-Não vai ao Nepal desde 2013;
-Necessita de deslocar-se ao Nepal para poder casar como seu noivo de nome …… nascido a 4 de Setembro de 1990 para mais tarde reagrupar o mesmo em território nacional ao abrigo do art.° 98°, n°1 da actual lei de estrangeiros;
-Ficou noiva em 2013, se demorar na obtenção definitiva do seu cartão de residência seguramente irá desfazer o seu casamento, correndo o sério risco de continuar só em Portugal e sem família.
-Pela sentença proferida, ora posta em causa, veio a ser indeferida liminarmente a petição inicial.
Do fundamentado e decidido na sentença se extrai, em síntese útil, que o julgador entende que os pressupostos previstos para a admissibilidade do mecanismo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias, não se verificam, uma vez que não está em causa a protecção de qualquer direito, liberdade ou garantia da Recorrente.
Esta, no fundamental, sustenta que lhe é legalmente consentido o uso do meio processual de que fez uso pelas razões atrás expostas.
O Recorrido, pelo seu lado, defende que apenas está a exigir à Recorrente que cumpram os requisitos legalmente previstos para a concessão da pretendida autorização.
Antecipe-se que a razão está do lado da Recorrido e do EPGA nos exactos termos expendidos no discurso jurídico da sentença por aqueles sufragados.
Se não, vejamos.
O processo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias cujos pressupostos estão expressos no art 109º do CPTA, é um meio processual urgente, de natureza principal e não cautelar, consistindo numas “das novidades absolutas” do CPTA, conforme dizem Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, in “Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª ed., 2007, pág., 629 e ss.), sendo um meio processual urgente inovador que se destina a salvaguardar o exercício de direitos, liberdades e garantias, mas cujo êxito está dependente da verificação dos pressupostos legalmente previstos.
Dispõe o art. 109º, nº 1 do CPTA que:
“1 - A intimação para projecção de direitos, liberdades e garantias pode ser requerida quando a célere emissão de uma decisão de mérito que imponha à Administração a adopção de uma conduta positiva ou negativa se revele indispensável ao exercício, em tempo útil, de um direito, liberdade ou garantia, por não ser possível ou suficiente, nas circunstâncias do caso, o decretamento provisório

de uma providência cautelas segundo o disposto no artigo 131º."

Extrai-se do inciso legal transcrito que estamos perante um processo principal, processo de intimação, cuja finalidade é a obtenção, por parte do interessado de uma sentença de condenação, mediante a qual o tribunal impõe a adopção de uma conduta, que tanto pode consistir numa acção (conduta positiva ou de facere), como consistir numa abstenção (conduta negativa ou de non facere).

E também decorre daquele preceito que estamos perante um processo destinado a proteger direitos, liberdades e garantias, sejam eles pessoais ou patrimoniais, posto que se verifique o preenchimento dos requisitos (dois) contidos no nº 1 do art. 109º do CPTA: situação de especial urgência carecida de tutela definitiva através da prolação de uma decisão de intimação para assegurar o exercício, em tempo útil, de um direito, liberdade ou garantia (1º); que a célere intimação se revele indispensável por não ser possível, nas circunstâncias do caso, o decretamento provisório de uma providência cautelar (2º), de acordo com o disposto no artigo 131º, nº 1 do CPTA.

Flui com absoluta clareza deste 2º requisito - indispensabilidade da célere intimação, que a consagração legal deste processo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias não permite usar tal processo de intimação como uma "(...) via normal de reacção a utilizar em situações de lesão ou ameaça de lesão de direitos, liberdades e garantias.

A via normal de reacção é a da propositura de uma acção não urgente (acção administrativa comum ou acção administrativa especial), associada à dedução de um pedido de decretamento de providências cautelares, destinadas a assegurar a utilidade da sentença que, a seu tempo, vier a ser proferida no âmbito dessa acção. Só quando, no caso concreto, se verifique que a utilização da via normal não é possível ou suficiente para assegurar o exercício, em tempo útil, do direito, liberdade ou garantia é que deve entrar em cena o processo de intimação. (...)"- Cfr. Autores e obra supracitados, pág. 631 e ss.

Daí o carácter subsidiário do processo de intimação previsto no art. 109º do CPTA (cfr. sobre os requisitos deste meio processual, Acs. do TCAS de 03.05.07, Proc. 02402/07; de 27.05.07, Proc. 06235/07; de 25.10.07, Proc. 03074/07).

No caso dos autos não estão reunidos os requisitos legais acima apontados desde logo porque, não estão aqui em causa a ofensa de direitos fundamentais consagrados, designadamente, nos artigos 17.º (Regime dos direitos, liberdades e garantias: O regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos enunciados no título II e aos direitos fundamentais de natureza análoga), 18.º(Força jurídica: 1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas.); Artigo 43.º (Liberdade de aprender e ensinar); 53.º(Segurança no emprego); Artigo 58.º (Direito ao trabalho); Artigo 67.º (Família: 1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à protecção da sociedade e do Estado e à efectivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. 2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protecção da família: a) Promover a independência social e económica dos agregados familiares; b) Promover a criação e garantir o acesso a uma rede nacional de creches e de outros equipamentos sociais de apoio à família); Artigo 68.º (Paternidade e maternidade:1. Os pais e as mães têm direito à protecção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível acção em relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua

educação, com garantia de realização profissional e de participação na vida cívica do país.); 69.º (Infância: 1. As crianças têm direito à protecção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições); 73.º (Educação, cultura e ciência); 74.º (Ensino:1. Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. 2. Na realização da política de ensino incumbe ao Estado: a) Assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito; b) Criar um sistema público e desenvolver o sistema geral de educação pré-escolar; c) Garantir a educação permanente e eliminar o analfabetismo); 75.º (Ensino público, particular e cooperativo: 1. O Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. 2. O Estado reconhece e fiscaliza o ensino particular e cooperativo, nos termos da lei.).

Por outro lado, no caso concreto, não se verifica uma situação de especial urgência carecida de tutela definitiva, através da prolação de uma decisão de intimação para assegurar o exercício, em tempo útil, daquele direito. Isso porque a célere intimação não se afigura indispensável por ser suficiente, nas circunstâncias do caso, o decretamento provisório de uma providência cautelar, de acordo com o disposto no artigo 131º, nº 1 do CPTA como se demonstrou na sentença.

É que, como bem enfatiza o recorrido, a requerente não é titular de qualquer direito, liberdade ou garantia posto em crise por um acto administrativo pois não é titular de qualquer direito à concessão de um título que a habilite a permanecer e/ou a residir em Portugal, exigindo-se-lhe para efeito o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 23/2007, de 4/7, e, bem assim, no Decreto Regulamentar nº 84/2007, de 5/11, o que, in casu, não terá acontecido.

Concordamos ainda com o recorrido no sentido de que o art. 15.º nº1 da CRP consagra o Princípio da Equiparação ou do tratamento nacional, mas este princípio não é absoluto: o respectivo âmbito de aplicação abrange tão só os cidadãos estrangeiros cuja entrada e permanência tenha sido autorizada em conformidade com o regime previsto nos diplomas supra referidos, em nome dos interesses constitucionalmente tutelados por aqueles - a segurança interna e a ordem pública.

Isto porque, como também salienta o recorrido e se nos afigura pacífico, é princípio geral da regulação da circulação das pessoas, acolhido nas normas de direito interno e internacional, que nenhum cidadão estrangeiro pode entrar e/ou permanecer num país sem a competente autorização das suas autoridades.

Dito de outro modo: inexiste um direito de entrada e permanência em território nacional, cujo reconhecimento está dependente de autorização, em função do preenchimento de requisitos previstos na já referida Lei, em que pontifica e para o que ao caso releva, a exigência ao cidadão estrangeiro que no país pretenda exercer uma actividade profissional, que seja titular do competente visto consular, que no caso posto assume a forma de visto de residência para exercício de actividade profissional subordinada.

Donde que não existe na esfera jurídica da requerente qualquer direito a uma autorização de residência, sendo que a "existência de uma situação jurídica individualizada que caracterize um direito, liberdade e garantia (...) a ocorrência de uma situação, no caso concreto, de grave ameaça ou violação (...) não releva, por isso, a mera invocação genérica de um direito, liberdade e garantia (...) impõe-se a descrição de uma situação factual de ofensa ou preterição do direito fundamental

que possa justificar
(...) uma análise perfunctória de aparência do direito " (cf. Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto F.Cadilha, Comentário ao Código do Processo nos Tribunais Administrativos, Almedina, 3- Edição, 2010, pág. 722 e 723).
Resulta evidente nos autos que tal exigência não foi cumprida e é também incontroverso que na situação da recorrente era efectivamente possível ou suficiente, o recurso ao art. 131º, nº.2 do CPTA, já que " o requerente não se pode limitar a alegar a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de exercer os direitos: deve provar que, sob pena de perda irreversível de faculdades de exercício daquele, ou mesmo de desaparecimento do direito no seu todo " (cf. Carla Amado Gomes, Pretexto, Contexto e texto da intimação para direitos, liberdades e garantias, págs. 15 e 16).
E á patente que a requerente não logrou fazer essa imprescindível prova pois se limitou a invocar que a não concessão da autorização de residência desrespeita diversos direitos constitucionais que indica sem os substanciar devidamente, ficando-se por uma genérica invocação, sem demonstrar sequer a necessidade dos actos a praticar para a evitação de uma afronta ou compressão dos seus direitos.
Não é configurável, pois, a verifica da violação de qualquer direito, liberdade e garantia, nem tão pouco a necessidade e indispensabilidade da intimação para a sua defesa, pressupostos da utilização deste meio processual como o exige o art. 109.º n.°1 do CPTA, ocorrendo a excepção dilatória inominada de inadequação do meio processual, isso na senda dos Acórdãos do Tribunal Central Administrativo Sul, datados de 15/12/2016, em sede dos processos n.ºs 1453/16.0BELSB e 1668/16.1BELSB.
Da concatenação da factualidade supra apontada e tida em conta na decisão recorrida com o pedido formulado pela Autora de intimação da Entidade Demandada a emitir o título de residência da Autora, somos forçados a concluir que a decisão a proferir em sede cautelar, não esgota os efeitos da acção principal, sendo possível e suficiente o decretamento de uma providência cautelar, no âmbito de uma acção administrativa para acautelar os invocados direitos da Autora, não se verificando uma situação que imponha a célere emissão de uma decisão de mérito.
Nessa linha de entendimento se pronunciaram vários arestos de que se destaca o acórdão do TCA Sul, de 15/12/2016, proferido no processo n° 1668/16.1BELSB, em que se expendeu, com pertinência para o caso:
"Os requisitos de que depende a utilização da intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias - e acima enunciados - reconduzem-se aos seguintes critérios práticos:
1). o juiz do processo (não urgente) principal não chegaria a tempo de ditar a justiça para a situação, isto é, para protecção de um direito, liberdade ou garantia;
2) o juiz da causa cautelar se ditasse a justiça para a situação teria antecipado ilegitimamente a decisão de mérito.
(...) não se verifica o pressuposto supra enunciado sob o n° 2) - impossibilidade ou insuficiência do decretamento provisório de uma providência cautelar no âmbito de uma acção administrativa -, dado que é possível e é suficiente o decretamento de uma providência cautelar no âmbito de uma acção administrativa.
Com efeito, o recorrente poderá intentar uma acção administrativa, sendo-lhe possível obter a tutela

urgente dos direitos que invoca através de um processo cautelar, no qual formule pedido de intimação do recorrido a emitir, provisoriamente, o título de residência - neste sentido, Carla Amado Gomes Pretexto, contexto e texto da intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias, Março de 2003, pág. 21, in www.icjp.pt/sites/default/files /media/291-l 35.pdf (.. .)".

Diga-se ainda e em reforço argumentativo não despiciendo, como adverte o EPGA no seu douto parecer que nesta parte vimos seguindo, que a própria Autora alegou que quando formulou o pedido de concessão de autorização de residência no passado dia 29/09/2015, junto ao Posto de Atendimento de Alverca do SEF (PDA ALVERCA), por este Posto de Atendimento foi autorizada a prorrogação de permanência, nos termos do n.°1, do artigo 71.° e do n°2, do artigo 72.°, ambos da Lei 23/2007, de 4 de Julho.
Ora, decorre do disposto no artigo 71.°, n° 1 da referida Lei n°23/2007 que "Aos cidadãos estrangeiros admitidos em território nacional nos termos da presente lei que desejem permanecer no País por período de tempo superior ao inicialmente autorizado pode ser prorrogada a permanência".
"A prorrogação de permanência pode ser concedida: (...) Até 90 dias, prorrogáveis por um igual período, se o interessado for titular de um visto de curta duração ou tiver sido admitido no País sem exigência de visto'" — cfr. alínea d), do n.°1 do artigo 72.° da Lei n° 23/2007.
E, por força do disposto n° 2, do artigo 72.° da referida Lei "A prorrogação de permanência pode ser concedida, (...), na pendência de pedido de autorização de residência, bem como em casos devidamente fundamentados.'".
"A prorrogação de permanência concedida aos cidadãos admitidos no País sem exigência de visto e aos titulares de visto de curta duração é limitada a Portugal sempre que a estada exceda 90 dias por semestre, contados desde a data da primeira passagem das fronteiras externas."- cfr. n.° 4 do referido artigo 72.°.
É forçoso, pois, concluir que a Autora está autorizada a permanecer em Portugal na pendência do pedido de autorização de residência temporária, e, no que tange à necessidade de se deslocar ao Nepal, nada de concreto foi alegado que nos permita concluir que não o poderá fazer mediante pedido devidamente fundamentado que dirija à ER e que em caso de recusa não possa ser acautelado pela via cautelar.
Daí a conclusão geral e definitiva: o da Autora não tem de considerar-se um caso de “especial urgência” dos previstos no artº 111º do CPTA pois, pelo que já se disse, a petição não permite reconhecer a possibilidade de lesão iminente e irreversível dos direitos, liberdades e garantias invocados.
É, pois, inelutável que se verifica a excepção dilatória de falta de idoneidade do meio processual, o que invalida a instância já que, tendo o Mº Juiz apreciado as questões que prioritariamente se impunham e se ligavam a pressupostos processuais cuja verificação impedia o conhecimento de quaisquer outras questões.
Donde que, uma vez que o Tribunal a quo conheceu de uma excepção dilatória, consistente na falta de idoneidade do meio processual utilizado, isso impõe, como se disse, a prejudicialidade do conhecimento das restantes questões não cabendo conhecer da falta/errada/insuficiente fundamentação de facto, pois, tendo em conta que o conhecimento da excepção dilatória prejudica o

conhecimento dos restantes pedidos, nada mais se logrou provar com relevância para a decisão da arguida excepção de falta de idoneidade do meio processual.
Dito de outro modo: em via da procedência da ajuizada excepção não poderia, nem deveria, o Tribunal a quo conhecer dos demais factos ou reconhecer o défice instrutório da sentença, não merecendo a conduta do julgador qualquer censura também nesse plano.
Em face do exposto, tendo a Autora sido convidada a substituir a petição inicial, com o fundamento que a situação em causa nos presentes autos não é de molde a justificar o decretamento de uma intimação, em virtude da factualidade alegada não permitir concluir que estamos perante uma situação em que seja necessária a "célere emissão de uma decisão de mérito", "por não ser possível ou suficiente, (...) o decretamento de uma providência cautelar, segundo o disposto no artigo 131.°", do CPTA, ao invés, é possível e suficiente o decretamento de uma providência cautelar para acautelar a situação da Autora, enquanto não for decidida a acção principal (acção administrativa) e não tendo a Autora acedido ao convite, vindo alegar factos que em nada alteram a situação, como se referiu, impõe-se indeferir liminarmente a petição inicial - cfr. artigos 109.°, n.°1 e 110.°- A, n.°1 do CPTA.

*

3. -DECISÃO

Nesta conformidade, acordam, em conferência, os Juízes do 2º Juízo do Tribunal Central Administrativo Sul, em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.

**

Lisboa, 05-07-2017

(José Gomes Correia)
(António Vasconcelos)
(Pedro Marchão)

Acordão de 2018-04-05 (Processo nº 2442/17.3BELSB), de 5 de abril

Emitente: Tribunal Central Administrativo Sul

Tipo: Acordão

Processo: 2442/17.3BELSB

Fonte Direito: DECISÕES JUDICIAIS

Relator: PAULO PEREIRA GOUVEIA

Descritores: INTIMAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS-LIBERDADES-E-GARANTIAS; SUBSTITUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL POR REQUERIMENTO CAUTELAR

Informação da publicação

Data de Publicação: 2018-04-05

SUMÁRIO

I - Os artigos 109º ss do CPTA, que consagram uma espécie excecional de ação principal, vêm na sequência do artigo 20º, nº 5, da CRP e justificam-se pela imperatividade de tutelar o indivíduo contra o perigo acrescido de lesão dos direitos ligados à dignidade da pessoa humana e a outros direitos fundamentais análogos com conteúdo material minimamente determinado ao nível constitucional.II – Não há que fazer o convite previsto no artigo 110º-A, nº 1, do CPTA, se o tribunal concluir com segurança que o processo cautelar será inadmissível por a respetiva ação principal padecer de caducidade do direito de ação. Seria um ato processual inútil e, portanto, proibido.

TEXTO

ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, NA 1ª SECÇÃO DO TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL:

I - RELATÓRIO

M… I… S… intentou no Tribunal Administrativo de Círculo de LISBOA
processo de intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias
contra MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.
A pretensão apresentada foi: emissão do título de residência com carácter urgente.
Por despacho de tipo saneador de 20-12-2017, o referido tribunal veio a prolatar a decisão ora recorrida, julgando procedente a exceção dilatória de inidoneidade do meio processual utilizado (que designou como “falta de urgência e de subsidiariedade da presente intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias”) e, consequentemente, absolvendo a Entidade Requerida da instância.

*

Inconformado com tal decisão, o autor interpôs o presente recurso de apelação, formulando na sua alegação as seguintes conclusões:

1) A Sentença a quo é deficiente.

2) O Tribunal a quo confunde conceitos.

3) Até 31 de Julho do corrente o procedimento para art. 88°/2 tinha natureza excecional e não estava sujeito a qualquer tipo de prazo legal.

4) Somente a partir dessa data constitui uma garantia do cidadão Imigrante.

5) A sujeição a prazos legais para decisão correspondia nos antigos diplomas ao nº I do art.º 88º.

6) O Autor provou documentalmente que não vai ao Paquistão há mais de oito(s) anos rever a sua família.

7) Há uma lesão bastante séria em curso do direito à família que o tribunal a quo ignora por completo.

8) O Autor não tem opção nem tem estabilidade laboral estando a receber desde janeiro de 2016 abaixo do salário mínimo nacional.

9) A sentença a quo não valora nem pondera devidamente os valores constitucionais em causa.

10) Só o uso do presente instrumento legal garante eficazmente o cumprimento a Constituição da República Portuguesa.

11) O Tribunal a quo inexplicavelmente não deu cumprimento às diligências de prova requeridas na Réplica.

12) O Tribunal a quo não faz o convite para a propositura de uma providência cautelar como está obrigado por lei.

*

O recorrido contra-alegou, concluindo assim:

(Texto no original)

*

Cumpridos os demais trâmites processuais, importa agora apreciar e decidir em conferência.

*

DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO:

Os recursos, sendo dirigidos contra a decisão do tribunal recorrido e respetivos fundamentos, têm o seu âmbito objetivo delimitado pelo recorrente nas conclusões da sua alegação de recurso (cfr. artigos 144º/2 e 146/4 do CPTA, 5º, 608º/2, 635º/4/5, e 639º do CPC/2013, “ex vi” artigos 1º e 140º do CPTA), alegação que apenas pode incidir sobre as questões de facto e ou de direito[1] que tenham sido apreciadas pelo tribunal recorrido ou que devessem ser aí oficiosamente conhecidas. Sem prejuízo das especificidades do contencioso administrativo (cf. J. C. V… DE A…, A Justiça Administrativa – Lições, 15ª ed., pp. 411 ss; artigos 73º/4, 141º/2/3, 143º e 146º/1/3 do CPTA).

Por outro lado, nos termos do artigo 149.º do CPTA, o tribunal “ad quem”, em sede de recurso de apelação, não se limita a cassar a decisão judicial recorrida, porquanto, ainda que a revogue ou a anule (isto no sentido muito amplo utilizado no CPC), deve decidir o objeto da causa apresentada ao tribunal “a quo”, conhecendo de facto e de direito, desde que se mostrem reunidos nos autos os

pressupostos e condições legalmente exigidos para o efeito.
Assim, as questões a resolver neste recurso - contra a decisão recorrida – são as identificadas no ponto II.2, onde as apreciaremos.
*
II - FUNDAMENTAÇÃO
a)
Como referido, este tribunal está vinculado a analisar apenas as questões a resolver colocadas no recurso.
O TAC, após os articulados (momento legalmente duvidoso para adotar uma decisão ao abrigo do artigo 110º-A do CPA; assim: M… A…/C.C., Comentário ao CPTA, 4ª ed., notas ao artigo 110º-a; V… DE A…, A Justiça Administrativa, 15ª ed., p. 256), considerou que o tipo de ação utilizada pelo autor era inadequado ao fim pretendido, isto é, ao objeto processual; é a chamada inadequação do meio processual, uma exceção dilatória.
Para tal, considerou que o exigido no artigo 109º/1 do CPTA não se verificava no caso presente, sendo suficiente (e possível) solicitar o decretamento de uma providência cautelar. Nem há uma "urgência numa sentença definitiva", nem há um direito fundamental do autor do tipo ali previsto, a propósito da falta de decisão da entidade demandada no âmbito do artigo 88º da Lei nº 23/2007.
E fundamentou esse entendimento.
Depois, apesar de não se tratar de um despacho liminar (cf. artigo 110º-A/1 do CPTA), o TAC ponderou o caso à luz desta disposição legal. E concluiu que não havia que fazer o convite previsto no nº 1 de tal artigo 110º-A do CPTA, porque o direito de ação (principal), ação essa de que o "novo" processo cautelar (artigo 110º-a/1-in fine) seria instrumental, já estava caducado à luz do artigo 69º/1 do CPTA.
b)
O recorrente considera o despacho recorrido "deficiente", volta a discutir brevemente o artigo 88º da Lei 23/2007 e o direito fundamental à família, acabando por alegar ainda que o TAC deveria ter feito o convite referido no artigo 110º-A/1 cit.
c)
Como é amplamente sublinhado, os artigos 109º ss do CPTA, que consagram uma espécie excecional de ação principal, vêm na sequência do artigo 20º/5 da CRP e justificam-se pela consciência de tutelar o individuo contra o perigo acrescido de lesão dos direitos ligados à dignidade da pessoa humana e a outros direitos fundamentais análogos, com conteúdo material minimamente determinado ao nível constitucional (neste sentido, cf. V… DE A…, ob. cit., p. 253).
Apreciando o recurso:
O despacho recorrido não é deficiente ou confuso. É claro, suficiente e explana-se bem. Já o resumimos supra.
Por outro lado, não releva a questão abordada no recurso quanto ao atual ou ao anterior artigo 88º/2 da Lei 23/2007 (autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada)[2], face ao despacho recorrido, que, aliás, nem abordou tal questão de direito substantivo. O que é natural, pois que o TAC apreciava uma exceção dilatória, estando assim numa fase processual e num momento lógico anteriores a uma seleção de factos relevantes para o fundo da causa.

O mesmo é de dizer, logicamente, quanto a diligencias de prova.
E, como é questão ausente do despacho recorrido, este tribunal de recurso não a pode apreciar, como já supra se explicou.
O mesmo se afirma quanto à questão do alegado direito à família.
Finalmente, quanto à violação do dever de fazer o cit. convite a que se refere o artigo 110º-A/1 do CPTA: embora o recurso seja vago nesta questão central, a verdade é que seria uma nulidade processual fazer-se tal convite ao autor, seria um ato inútil, já que o TAC considerou – e bem (o que nem vem questionado!) – que o direito à ação principal em causa (que o TAC expõe corretamente) já caducara, como vimos supra. Houve um pedido do particular para beneficiar do artigo 88º/2 cit., a A.P. ficou obrigada a decidir no prazo geral (vd. artigos 13º, 86º, 128º e 129º do CPA), mas não o fez; assim se aplicará ao caso, a final, o artigo 69º/1 do CPTA.
E, com tal direito caducado antes deste processo, como de facto está (vd. o art. 69º/1 do CPTA e os factos aludidos no despacho recorrido, não questionados minimamente aqui), convidar o autor a deduzir um processo cautelar como instrumento de tal ação principal (MÁRIO AROSO/C.C., Comentário…, 4ª ed., p. 906), substituindo a p.i. por um r.i. e um pedido cautelar, seria um contrassenso e algo de proibido pelo artigo 130º do CPC, com referência ao imperativo artigo 116º/2-f) do CPTA, artigo que o mesmo tribunal iria aplicar em sede do processo cautelar vindo da convolação.
Daí o acerto do decidido pelo TAC.
Portanto:
- este processo não é o legalmente adequado ao seu objeto, violando os pressupostos previstos no artigo 109º/1 do CPTA, por ser perfeitamente possível e suficiente solicitar uma providencia cautelar;
- e, atentos os factos constantes dos articulados e os artigos 69º/1 e 116º/2-f) do CPTA, não é legalmente possível, porque inútil, convolar este processo em processo cautelar nos termos do artigo 110º-A do CPTA, sendo assim desnecessário fazer o convite previsto nesta disposição legal.
*
III - DECISÃO
Por tudo quanto vem de ser exposto e de harmonia com os poderes conferidos no artigo 202º da Constituição, acordam os juizes da Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal Central Administrativo Sul em negar provimento ao recurso.
Sem custas (cf. artigo 4º/2-b) do RCP).
Registe-se e notifique-se.
Lisboa, 05-04-2018

Paulo H. Pereira Gouveia – Relator

Catarina Jarmela

[1] Tendo sempre presente que o Direito é uma ciência social especialmente condicionada pela linguagem.

[2] 1 - Para além dos requisitos gerais estabelecidos no artigo 77.º, só é concedida autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada a nacionais de Estados terceiros que tenham contrato de trabalho celebrado nos termos da lei e estejam inscritos na segurança social.

2 - Mediante manifestação de interesse apresentada através do sítio do SEF na Internet ou diretamente numa das suas delegações regionais, é dispensado o requisito previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 77.º, desde que o cidadão estrangeiro, além das demais condições gerais previstas naquela disposição, preencha as seguintes condições:

a) Possua um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho ou tenha uma relação laboral comprovada por sindicato, por representante de comunidades migrantes com assento no Conselho para as Migrações ou pela Autoridade para as Condições do Trabalho;

b) Tenha entrado legalmente em território nacional;

c) Esteja inscrito na segurança social, salvo os casos em que o documento apresentado nos termos da alínea a) seja uma promessa de contrato de trabalho.

3 - (Revogado.)

4 - A concessão de autorização de residência nos termos dos números anteriores é comunicada pelo SEF, por via eletrónica, à Autoridade para as Condições de Trabalho ou, nas regiões autónomas, à respetiva secretaria regional, de modo que estas entidades possam fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações legais da entidade patronal para com o titular da autorização de residência, bem como à administração fiscal e aos serviços competentes da segurança social.

5 - O titular de uma autorização de residência para exercício de uma atividade profissional subordinada pode exercer uma atividade profissional independente, mediante substituição do título de residência, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo seguinte.

Redação anterior, de 2012:

Excecionalmente, mediante proposta do diretor nacional do SEF ou por iniciativa do membro do Governo responsável pela área da administração interna, pode ser dispensado o requisito previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 77.º, desde que o cidadão estrangeiro, além das demais condições gerais previstas nessa disposição, preencha as seguintes condições:

a) Possua um contrato de trabalho ou tenha uma relação laboral comprovada por sindicato, por associação com assento no Conselho Consultivo ou pela Autoridade para as Condições de Trabalho;

b) Tenha entrado legalmente em território nacional e aqui permaneça legalmente;

c) Esteja inscrito e tenha a sua situação regularizada perante a segurança social.

Acordão de 2016-12-15 (Processo nº 1668/16.1.BELSB), de 15 de dezembro

Emitente: Tribunal Central Administrativo Sul

Tipo: Acordão

Processo: 1668/16.1.BELSB

Fonte Direito: DECISÕES JUDICIAIS

Relator: CATARINA JARMELA

Descritores: INTIMAÇÃO PARA PROTECÇÃO DE DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS; ARTIGO 109º, DO CPTA ; TÍTULO DE RESIDÊNCIA

Informação da publicação

Data de Publicação: 2016-12-15

SUMÁRIO

I – Do art. 109º n.º 1, do CPTA, resulta que a utilização da intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias depende dos seguintes pressupostos:1) - a necessidade de emissão urgente de uma decisão de mérito seja indispensável para protecção de um direito, liberdade ou garantia; 2) - não seja possível ou suficiente o decretamento provisório de uma providência cautelar no âmbito de uma acção administrativa normal,os quais se reconduzem aos seguintes critérios práticos:1) - o juiz do processo (não urgente) principal não chegaria a tempo de ditar a justiça para a situação, isto é, para protecção de um direito, liberdade ou garantia;2) - o juiz da causa cautelar se ditasse a justiça para a situação teria antecipado ilegitimamente a decisão de mérito.II – Invocando o recorrente que tem direito à emissão do título de residência, pois o pedido de autorização de residência já foi objecto de despacho de deferimento, a questão para a qual é solicitada tutela não pode ser resolvida através do processo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias por falta de invocação de qualquer situação concreta de urgência a exigir uma decisão de fundo no âmbito desse processo (pois nomeadamente nada é alegado no sentido de que, se a decisão de mérito não for proferida num processo urgente, haverá uma perda irreversível de faculdades de exercício do direito em causa ou uma qualquer situação de carência pessoal ou familiar em que esteja em causa a imediata e directa sobrevivência pessoal de alguém).III – Mesmo que, assim, não se entenda, sempre seria de manter a decisão recorrida que considerou inidóneo o meio processual usado (intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias), já que é possível e suficiente o decretamento de uma providência cautelar - no qual seja formulado pedido de intimação do recorrido a emitir, provisoriamente, o título de residência - no âmbito de uma acção administrativa.

TEXTO

*

I – RELATÓRIO

Nasir …….. intentou no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa a presente intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias, ao abrigo do art. 109º, do CPTA, contra o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, peticionando a condenação do réu a emitir-lhe o título de residência, bem como a aplicar a sanção pecuniária compulsória, prevista no art. 169º, do CPTA, por cada dia de incumprimento da sentença.

Por decisão de 14 de Setembro de 2016 do referido tribunal foi julgada procedente a excepção inominada da inadequação ou inidoneidade do meio processual, arguida pelo réu, e, consequentemente, foi o mesmo absolvido da instância.

Inconformado, o autor interpôs recurso jurisdicional para este TCA Sul, tendo na alegação apresentada formulado as seguintes conclusões:
“A - Não foram considerados pelo Tribunal a quo os seguintes factos com relevância para a apreciação e decisão do mérito da acção:
a) Em 15/10/2015, o Autor requereu ao SEF a concessão de autorização de residência, e na mesma data concluiu o seu pedido de concessão de autorização de residência; nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 88º, da Lei 23/2007, de 4 de Julho, no Posto de Atendimento do SEF de Alverca.
b) Na mesma data, o Autor pagou todas as taxas devidas pela conclusão do seu pedido de concessão de autorização de residência (incluindo-se nestas, aas taxas no valor de 276,30 Euros com referência à emissão e envio do título de residência temporária).
c) Na mesma data, pelo Posto de Atendimento do SEF de Alverca foi proferido Parecer Positivo de concessão de autorização de residência.
d) No mesmo dia, pelo Posto de Atendimento do SEF de Alverca foi proferido Despacho concedendo autorização de residência.
e) Na mesma data, foi concedido Visto - fls. … do PA.; e que é o visto válido e que subjaz e sustenta a emissão do título de residência.
f) O Réu limitou-se a apresentar requerimento nos autos de que aqueles pedidos de concessão de autorização de residência estão a ser objecto de reapreciação.
g) A contrario, o Réu não logrou provar quaisquer factos que obstem à apreciação/reapreciação e/ou à decisão do pedido formulado pelo Autor.
h) O Título de Residência nada mais é que a "tradução física" do "acto (administrativo) de concessão de autorização de residência".
i) O Título de Residência substitui, para todos os efeitos legais, o documento de identificação (artigo 84º da Lei 23/2007) .
j) O Título de Residência é, presentemente, o documento de identificação de cidadãos estrangeiros residentes legais; uma vez que já não existe o bilhete de identidade para cidadãos estrangeiros - vide o disposto no artigo 70º, n.º 1, do Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro.

k) A Lei (alínea c), do n.º 2, do artigo 2º da Lei 5/95, de 21 de Fevereiro, determina a obrigatoriedade de porte do título de residência

l) O n.º 2, do artigo 70º do Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro, determina que "ao título de residência são aplicáveis, com as devidas adaptações, as normas relativas à identificação civil" .

m) O prazo para a emissão do Título de Residência; à semelhança das "normas relativas à identificação civil", varia entre os 10 e os 30 dias.

n) Até à presente data, e decorridos que são quase DOZE meses sobre a conclusão do seu pedido, o Autor não recebeu o seu Título de Residência.

o) O Autor invocou a necessidade da posse do título de residência, para o exercício efectivo dos seus direitos à identidade pessoal, o direito ao trabalho, o direito à segurança, direito à saúde, e direito à família.

B - Face à prova produzida nos autos, e tendo o Autor formulado o pedido, instruído o pedido, e pago das taxas devidas, e nada tendo sido alegado ou provado pelo Réu que obste à satisfação do pedido e pretensão do Autor nos presentes autos, devia ter sido o Réu condenado a emitir o título.

C - O Autor reclamou o direito à emissão do seu título de residência; porque formulou o seu pedido, instruído o mesmo, pagou das taxas devidas; nada tendo sido alegado ou provado pelo Réu que obste à satisfação do seu pedido e à pretensão do Autor.

D - Ainda que se considere que o Autor apresentou o seu pedido de concessão de autorização de residência em 15/10/2015 e que deve aguardar pela "decisão" do Réu, e que não que concluiu o seu pedido nessa data (como defende o Autor), então temos que concluir que o seu pedido foi objecto de deferimento tácito (artigo 82º, n.º 3, da Lei 23/2007).

E - Quer se considere o prazo geral (artigo 86º, n.º 1, do CPA), ou o prazo, especial (artigo 82º, nº 1, da Lei 23/2007), temos que ambos - no caso sub judice - se encontram extrapolados.

F - Citando Tiago Fidalgo de Freitas in "O regime jurídico da imigração: a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional" - Centro de Estudos Judiciários (CEJ) refere: "Após análise detalhada das condições elencadas nos parágrafos anteriores, pode-se concluir que não existe uma discricionariedade administrativa na decisão de conceder ou não a autorização de residência. Desta forma, pode falar-se, também aqui, de um direito à concessão da autorização de residência ."

G - Mesmo no caso das autorizações de residência emitidas as abrigo do chamado "regime excepcional" (para os cidadãos que não preencham os requisitos dos restantes tipos de autorização de residência), o SEF está adstrito a agir em conformidade com os princípios constitucionais da actividade administrativa, ou seja, os princípios da prossecução do interesse público, do respeito pelos direitos e interesses dos cidadãos, da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé (cfr. artigo 266º da Constituição).

H - O Réu violou, em especial, os princípios da decisão (artigo 13º do CPA); da eficiência (artigo 5º do CPA), e da celeridade (artigo 59º do CPA).

I - O princípio constitucional (da equiparação) abrange: direitos fundamentais, direitos económicos, sociais e culturais, direitos civis, e direitos (limitados) de participação política.

J - Entre os direitos, liberdades e garantias pessoais que a CRP garante "a todos", conta-se

nomeadamente o direito à identidade pessoal, o direito à segurança e o direito à segurança no trabalho, direitos invocados pelo Autor.

L - E, entre os direitos sociais, económicos e culturais, temos o direito dos estrangeiros ao acesso ao trabalho (condicionado é claro que a requisitos prévios; como a obtenção de um título válido de permanência (visto de trabalho, AR ou AP); e que como se deixou alegado, foi objecto de deferimento tácito); direito à segurança social, direito à protecção da saúde e acesso ao SNS.

M - O estatuto de titular de autorização de residência abrange, por seu turno artigo 83º da Lei 23/2007), e entre outros direitos de acesso: o direito ao exercício de uma actividade profissional subordinada ou independente; e o direito à saúde.

N - A violação de qualquer um destes direitos - à luz da sua impossibilidade de exercício pela omissão de emissão do título de residência - não foi considerado pelo douto tribunal a quo.

O - Se o estrangeiro/Autor não consegue fazer prova dessa autorização - cuja expressão física consiste título de residência - como ficam esses direitos, ou o exercício dos mesmos?

P - Qual a dimensão prática desses direitos?

Q - Terá o Autor que aguardar pela sua violação para, então, recorrer ao presente procedimento de Intimação?

R - A razão que subjaz ao procedimento da Intimação não é assegurar; permitir, viabilizar o exercício pleno, seguro, incondicional, sem constrangimentos, desses direitos?

S - Ou, já se admite a "suspensão" desses direitos, e do seu exercício, perante questão meramente burocráticas?

T - O legislador consagrou forma típicas para reagir contra violações de direitos ou interesses legalmente protegidos ou para pretensões deduzidas em juízo.

U - A idoneidade ou propriedade do meio processual afere-se pela pretensão que se intenta ou deseja fazer valer, ou seja, pelo pedido formulado (veja-se António Santos Abrantes Geraldes in "Temas da Reforma do Processo Civil" , Almedina 1997, pág. 247; bem como assim Lebre de Freitas in "Código do processo Civil Anotado", Coimbra Editora, 1999, 1Volv. II, pág. 344).

V - O artigo 109º, n.º 1, do CPTA prevê que "A intimação para protecção de direitos, liberdades e garantais pode ser requerida quando a célere emissão de uma decisão de mérito que imponha à Administração a adopção de uma conduta positiva ou negativa se revele indispensável para assegurar o exercício em tempo útil de um direito, liberdade, garantia, por não ser possível ou suficiente nas circunstâncias do caso o decretamento provisório de uma providência cautelar.".

X - O artigo 20º da Constituição estabelece: "A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus Direitos e Interesses legalmente protegidos, não podendo a Justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos.".

Z - Para defesa dos Direitos, Liberdades e Garantias pessoais, a Lei assegura, pois, procedimentos caracterizados pela celeridade e prioridade; de modo a obter a tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses Direitos.

AA - O presente processo é um processo de Intimação, o que significa que se trata de um processo dirigido à emissão de uma sentença de condenação, mediante a qual o tribunal impõe a adopção de uma conduta; que tanto pode consistir num facere, como num non facere; numa uma conduta positiva (acção) ou numa conduta

negativa (abstenção).
BB - No caso dos autos sub judice estão em causa Direitos que são corolários do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º da CRP) em que se funda o Estado de Direito democrático, e enquanto princípio fundamental do Estado Português consagrado no artigo 2º da CRP.
CC - Prevê o artigo 17º da CRP; que tem como epígrafe, "Regime dos Direitos, Liberdades e Garantias": "O regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos enunciados no título II e aos direitos fundamentais de natureza análoga.".
DD - Este artigo dá expressão a uma norma chave para compreensão do regime constitucional dos direitos fundamentais. Ele pressupõe a distinção entre duas categorias de direitos fundamentais com regime próprio, nomeadamente os direitos, liberdades e garantias e dos direitos económicos, sociais, culturais enunciados respectivamente nos Títulos II e III da CRP.
EE - De acordo com estes critérios, serão de considerar como direitos fundamentais de natureza análoga aos Direitos, Liberdades, Garantias, entre outros o acesso do direito e aos tribunais (cfr. artigo 20º da CRP).
FF - Os direitos constitucionais de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias aproveitam o regime constitucional próprio destes em toda a sua extensão, tanto nos aspectos materiais desse regime como na sua sua dimensão orgânica (veja-se Gomes Canotilho e Vital Moreira in "Constituição da República Portuguesa Anotada", Coimbra Editora, págs. 140 e ss).
GG - Pelo exposto o presente meio processual é o mais adequado à defesa dos Direitos em causa.
HH - Ainda o artigo 107º do CPTA, o qual estabelece que este processo há-de aplicar se a situações relativas à protecção de Direitos, Liberdades e Garantias em que estejam presentes os pressupostos da indispensabilidade e da urgência. Isto é, quando não seja possível lançar mão de outro meio adequado em tempo útil para acautelar o lesado ou em vias de ser lesado.
II - Citando Isabel Celeste M. Fonseca in "Dos Novos Processos Urgentes no Contencioso Administrativo" in Lex, Lisboa, 2004, pág. 79: "subjacente à necessidade da Intimação Urgente e definitiva existe uma situação de urgência, mas para a qual não servem as vias processuais comuns, porque são lentas demais, nem presta a medida cautelar urgentíssima. E esta não serve por uma razão: porque é uma medida cautelar, por isso mesmo, porque é caracterizada pela provisoriedade. E, não satisfazendo no caso concreto o regulamento provisório, ela deve ser preterida perante o processo urgente que julgue definitivamente o mérito da causa.".
JJ - Ainda: "para compreender os pressupostos da admissibilidade da Intimação para Protecção de Direitos, Liberdades e Garantias, deve partir-se da consideração da absoluta necessidade de emissão de uma decisão de mérito pela facto de uma medida cautelar se revelar, em certo caso, como impossível ou insuficiente.".
LL - A presente Intimação é um processo principal com natureza urgente que tem como função essencial a de assegurar o exercício em tempo legal útil de um Direito, Liberdade e Garantia, por não ser possível ou suficiente o decretamento provisório de uma providência cautelar.
MM - No caso concreto defendemos que estamos perante uma situação de especial urgência porquanto o Autor se encontra materialmente impossibilitado de (e, por falta de documento de identificação suficiente enquanto estrangeiro em território nacional) de - e, em tempo útil - ter acesso

ao sistema de saúde em igualdade com os demais; a trabalhar e viver do seu trabalho; a viver com traquilidade; a poder deslocar-se; e impossibilitado de rever a sua família ou iniciar o competente processo de reagrupamento familiar.

NN - Estão em crise os direito ao casamento, à família, ao trabalho, ao acesso a trabalho, à segurança no trabalho, à identificação pessoal, à saúde e acesso á saúde; entre outros.

OO - A emissão do Título de Residência revela-se absolutamente fundamental para assegurar em tempo útil o princípio da equiparação dos cidadãos estrangeiros aos cidadãos portugueses.

PP - Não se vislumbrando em quanto tempo o Título de Residência será emitido.

QQ - Conclui-se inevitavelmente que uma decisão cautelar seria completamente desadequada e somado ao facto da demora previsível na decisão no processo principal. A tutela cautelar esgotaria os efeitos da acção principal.

RR - Cada dia que passa é menos um dia para efectivação dos direitos constitucionais do Autor.

SS - A demora na emissão do Título de Residência lesa seriamente os direitos constitucionais do Autor; estando-se perante uma situação a qual para ser acautelada impõe uma pronúncia definitiva sobre o mérito da causa.

TT - Mais que uma questão legal, temos uma questão MORAL: o Estado Português NÃO pode receber milhares de euros em taxas de centenas de cidadãos, a título de emissão e envio dos seus títulos de residência, e de valor superior a um salário mínimo nacional, e depois, vir negar a emissão dos mesmos.

UU - E, simultaneamente, negar a sua identidade enquanto estrangeiro em território nacional.

VV - O que é isto senão uma forma de opressão?!

XX - O Autor pagou, e é um prisioneiro; porque não tem identidade; porque tem medo de andar na rua, porque está sujeito à exploração laboral; por exemplo.

ZZ - Estão preenchidos os pressupostos cumulativos da intimação para proteção de direitos, liberdades e garantais: a) a providência destina-se a proteger um direito, liberdade e garantia; b) a conduta do Réu é ilícita; c) a providência requerida é indispensável, por ser a mais eficaz do ponto de vista da tutela jurisdicional efectiva, para assegurar, a título definitivo, o exercício em tempo útil ou evitar a lesão do direito, liberdade ou garantia, e d) não ser possível ou suficiente qualquer outro meio processual principal.

AAA - No sentido da adequação do meio processual, veja-se ainda a seguinte jurisprudência:

STA

d)Rec. Nº 783/11 do STA (processo 07694/11 do TCA SUL) de 24/01/2012.

e) Rec. Nº 442/11-12 do STA de 27 de Julho de 2011.

f) Rec. Nº 113/11 do STA (processo n º 06606/10 do TCA SUL) de 03 de Maio de 2011.

TCA SUL

b) Acórdão, processo nº 10986/14-22 Juízo-2ª secção datado de 03 de Abril de 2014.

TAC de LISBOA

p) Proc. nº 2567/06.0 BELRS (Tribunal Administrativo e Fiscal-Lisboa 2)

q) Proc. nº 1947/09.4 BELSB

r) Proc. nº 2545/09.8BELSB

s) Proc. nº 2419/13.8 BELSB

t) Proc. nº 2046/12.7 BELSB
u) Proc. nº 1226/14.5 BELSB
v) Proc. nº 2790/14.4 BELSB
w) Proc. nº 475/16.6 BELSB
todos eles visitáveis em www.Dgsi.pt.
TERMOS EM QUE SE CONCLUI NO SENTIDO DE E COM O MUI DOUTO PROVIMENTO DE VOSSAS EXAS:
A) SER REVOGADA A SENTENÇA DO TRIBUNAL A QUO.
B) SER CONSIDERADO PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO.
C) SEJA CONFIRMADO COMO LIMITE TEMPORAL INSTRUTÓRIO OU DECISÓRIO PARA A CONCESSÃO DE RESIDÊNCIA POR VIA DO ART2 88º,2, O PRAZO MÁXIMO DE SESSENTA DIAS.
E) OU, O PRAZO DE DEZ DIAS; POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 86º, N. 1, DO CPA.
F) DEVE DECLARAR-SE O DFERIMENTO TÁCITO DA CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA, ATENTO O DECURSO DO TEMPO E PELA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
G) DEVE O RÉU SER INTIMADO A EMITIR O TÍTULO DE RESIDÊNCIA RELATIVO AO AUTOR .
H) NO MAIS DEVE SER DECLARADA COMO PROCEDENTE E PROVADA A INTIMAÇÃO.
ASSIM SE FARÁ JUSTIÇA!".

O recorrida, notificado, apresentou contra-alegação na qual pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público junto deste TCA Sul emitiu parecer no sentido da improcedência do presente recurso jurisdicional, posicionamento esse que, objecto de contraditório, não mereceu qualquer resposta.

II - FUNDAMENTAÇÃO
Na decisão recorrida foi considerada como assente a seguinte factualidade:
«A) No dia 15 de Outubro de 2015, requereu ao SEF a concessão de autorização de residência nos termos do art.º 88º, n.º 2, da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, "na sua actual versão" (fl.s 1 do PA, cujo teor se dá por reproduzido);
B) Na mesma data (15 de Outubro de 2015) e no Posto de Atendimento de Alverca do SEF foi autorizada a "prorrogação da permanência por 561 dias nos termos do n. 1 do art. 71 e do n. 2 do art. 72 da Lei n. 23/2007, de 4 de Julho" (fl.s 32, verso, do PA, cujo teor se dá por reproduzido);
C) Tendo o Requerente pago, na mesma data (15 de Outubro de 2015), os montantes mencionados no doc. 1 junto ao r.i. e cujo teor se dá por reproduzido;
D) Em 23 de Junho de 2016, o Requerente solicitou ao "Director Regional do SEF – DRLVTA" informação sobre o estado e solicitou a emissão e envio do seu título de residência (doc. 2 junto ao r.i. e cujo teor se dá por reproduzido);
E) O envio do requerimento inicial "via site" foi registado no SITAF no dia 19 de Julho de 2016;

F) O título de residência ainda não foi emitido (alegação não impugnada)».

Nos termos do art. 662º n.º 1, do CPC de 2013, ex vi art. 140º n.º 3, do CPTA (na redacção dada pelo 214-G/2015, de 2/10, tal como as demais referências feitas ao CPTA neste acórdão), procede-se à alteração da factualidade dada como provada nos seguintes termos:

- O facto B) é substituído pelo seguinte facto:
B) Em 15 de Outubro de 2015 e no Posto de Atendimento de Alverca do SEF foi concedida prorrogação de permanência ao autor por 561 dias, nos termos do n.º 1 do art. 71º e do n.º 2 do art. 72º, da Lei 23/2007, de 4 de Julho, com referência ao período de 2 de Abril de 2014 a 14 de Outubro de 2015, na sequência da emissão de parecer nesse mesmo sentido (cfr. fls. 32, do processo administrativo).

- São aditados os seguintes factos G) a I):
G) O requerimento referido em A) foi acompanhado dos documentos constante de fls. 2 a 10, 12 a 25 e 27 a 30, do processo administrativo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
H) Em 21.3.2016 a Directora Nacional do SEF proferiu o seguinte despacho:
“ « (Texto no original)»

” (cfr. Doc. 1, junto com a contestação).
I) E em 4.7.2016 a Directora Nacional do SEF proferiu o seguinte despacho:
“« (Texto no original)»
” (cfr. Doc. 2, junto com a contestação).

*
Presente a factualidade antecedente, cumpre entrar na análise dos fundamentos do presente recurso jurisdicional.
As questões suscitadas resumem-se, em suma, em determinar se a decisão recorrida incorreu em erro:
- na fixação da matéria de facto;
- ao ter julgado procedente a excepção de inidoneidade do meio processual usado e, em caso afirmativo, se deverá ser julgado procedente o pedido de intimação do recorrido a emitir o título de residência relativo ao recorrente (cfr. alegação de recurso e respectivas conclusões, supra transcritas).
Erro na fixação da matéria de facto

O recorrente pretende o aditamento, à factualidade dada como provada na decisão recorrida, do invocado nas alíneas a) a o), da conclusão A), da sua alegação de recurso.

Quanto à questão do aditamento dos factos alegados na alínea f), a mesma já se encontra corrigida por este tribunal, nos termos supra referidos, ao abrigo dos poderes conferidos pelo art. 662º n.º 1,

do CPC de 2013 (cfr. factos aditados como H) e I)).

Relativamente ao invocado na alínea e), tal impugnação terá de ser rejeitada por falta de cumprimento do ónus previsto no art. 640º n.º 1, al. b), do CPC de 2013. Com efeito, encontrando-se numerado o processo administrativo, teria de ser indicada a página (com referência ao respectivo número) que permite a prova do facto em questão, o que não foi feito. De todo o modo, sublinha-se que, compulsado o processo administrativo, não se detecta no mesmo qualquer documento relativo ao facto em questão.

No remanescente falece a razão ao recorrente, dado que:
- o alegado nas alíneas a) e b) já consta da factualidade dada como provada (cfr. alíneas A) e C), bem como alínea G), esta aditada ao abrigo dos poderes conferidos pelo art. 662º n.º 1, do CPC de 2013);
- quanto ao invocado nas alíneas c) e d), antes se provou o que consta da factualidade dada como provada sob a alínea B) (ou seja, que foi concedida prorrogação de permanência e não autorização de residência – cfr., quanto à distinção, os capítulos V (arts. 71º a 73º) e VI (arts. 74º a 124º), da Lei 23/2007, de 4/7);
- o afirmado nas alíneas g) a m) e o) corresponde a conclusões jurídicas;
- o alegado na alínea n) já consta da factualidade dada como provada (cfr. alínea F)).
Erro da decisão recorrida ao julgar procedente a excepção de inidoneidade do meio processual usado

A decisão recorrida considerou procedente a excepção de inidoneidade do meio processual usado, arguida pelo recorrido, com base nomeadamente na seguinte argumentação:
“Em circunstâncias normais, qualquer dos meios processuais principais não urgentes é idóneo a tutelar direitos, liberdades e garantias ou outros direitos fundamentais de natureza análoga.
O tipo de intimação de que ora se trata é um meio processual transversal, no sentido de que é adequado à actuação em juízo, no domínio dos direitos, liberdades e garantias e nas condições previstas no art.º 109º do CPTA , das pretensões que constituem o objecto típico dos meios processuais principais não urgentes previstos por lei, seja na fase declarativa seja na fase executiva, nomeadamente a acção administrativa e os processos executivos correspondentes. Visa a protecção do direito, liberdade ou garantia em si mesmo considerado – uma protecção directa e não por via indirecta da protecção de qualquer outro direito não qualificável como direito, liberdade ou garantia ou como direito fundamental de natureza análoga, pois que, de outro modo, estaria legitimado o recurso à intimação para protecção de qualquer outra categoria de direitos, incluindo direitos não fundamentais, já que, em tese, a generalidade dos direitos pode, em último termo, ser reconduzido ao direito ao desenvolvimento da personalidade, garantido pelo art.º 26º, n.º 1, da Constituição.
O que justifica o recurso à intimação para a protecção de direitos, liberdades e garantias é a particular urgência da necessidade de uma decisão de mérito imediata e definitiva que proteja o direito, liberdade ou garantia ou o direito fundamental de natureza análoga, sob pena de a sua lesão se tornar inevitável.

Nos termos do art.º 109º do CPTA são pressupostos cumulativos da intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias: (i) que a providência judiciária requerida (adopção ou abstenção de uma conduta) se destine a proteger um direito, liberdade e garantia dos previstos no Título II da Parte I da Constituição ou um direito fundamental de natureza análoga (art.º 17º da Constituição), de cariz pessoal ou patrimonial (já que a lei não distingue); (ii) contra uma conduta ilegal ou ilícita; (iii) que a providência judiciária requerida seja indispensável, por ser a mais eficaz do ponto de vista da tutela jurisdicional efectiva, para assegurar, a título definitivo, o exercício em tempo útil ou evitar a eclosão ou a consumação da lesão do direito, liberdade ou garantia em causa; (iv) por não ser possível ou suficiente qualquer outro meio processual principal (acção administrativa), combinado com o decretamento provisório de uma providência cautelar adequada às circunstâncias do caso.
O juízo sobre a verificação ou não do pressuposto (ii) implica a apreciação do mérito da causa. Os restantes pressupostos, em boa verdade, são condições de procedibilidade, matéria adjectiva, cuja falta torna ilegítimo o uso do processo de intimação e impede o Tribunal de entrar na apreciação do mérito da causa.
Trata-se de um meio processual principal, de carácter célere e subsidiário e que culmina numa decisão de mérito sobre a pretensão do requerente “no prazo necessário para assegurar o efeito útil da decisão”, mas não superior a cinco dias (art.º 111º, n.º 1, do CPTA), sendo que a celeridade varia consoante o grau de urgência da situação e da maior ou menor complexidade da matéria, os quais, no limite, podem impor uma decisão em 48 oito horas nos termos do art.º 110º, n.º 3, al. c), do CPTA (situações de urgência extrema) ou com uma tramitação menos célere, segundo o ritual da acção administrativa não urgente, embora com os prazos reduzidos a metade, nos termos do n.º 2 do referido art.º 110º, quando a complexidade da matéria o justifique.
Cabe ao requerente o ónus de alegar e provar a ocorrência de todos os pressupostos da intimação. Porque a intimação visa prevenir a lesão ou garantir o exercício do direito “em tempo útil”, este ónus inclui o dever de justificar a especial urgência mediante a indicação do momento limite, do ponto de referência temporal, ultrapassado o qual será inevitável a lesão irreversível ou se tornará, de todo, impossível exercer o direito: é o que resulta da expressão “em tempo útil” usada nos art.ºs 109º do CPTA.
Em suma, não basta invocar a violação ou o fundado receio de violação de um direito, liberdade e garantia ou de outro direito fundamental de natureza análoga nem a indispensabilidade da intimação em abstracto: o processo de intimação não se destina a remover umas dificuldades quaisquer no exercício de um direito, liberdade ou garantia ou de outro direito fundamental de natureza análoga, mas apenas a arredar aqueles obstáculos que se não forem afastados por meio de uma decisão de mérito dentro de prazo curto determinam o sacrifício do conteúdo essencial do direito ou inviabilizam na prática o seu exercício útil. A urgência e a indispensabilidade do exercício do direito que legitimam o uso do meio processual em causa têm de ser demonstradas e justificadas com factos concretos e objectivos, por referência a um direito, liberdade ou garantia concreto ou a uma sua dimensão concreta, numa circunstância concreta, temporalmente balizada, e não em abstracto.
Sendo vários, como vimos, os pressupostos da intimação e estando a procedência da pretensão do requerente dependente da verificação cumulativa de todos eles, não basta invocar, em abstracto, apenas um ou alguns deles, nomeadamente a ofensa de direitos fundamentais e a

indispensabilidade da intimação; é também necessário que se demonstre, em concreto, que se não for obtida, em dado período de tempo, a providência judiciária requerida, através do tipo de intimação usado, será impossível salvar o direito invocado ou o seu conteúdo útil. A situação de urgência invocada há-de ser objectiva, comprovável por qualquer pessoa que esteja "de fora" e ser demonstrada racionalmente no processo.
No casso em pauta, está em questão, tanto quanto resulta do modo como o Requerente conforma a lide, a emissão do título representativo e comprovativo da autorização de residência que o Requerente alega ter-lhe sido concedido.
(…)
(…) o Requerente não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a necessidade da emissão, em prazo certo e curto, do título de residência, sob pena de a emissão se tornar materialmente ou legalmente impossível ou de o Requerente o não poder usar em tempo útil. Que se saiba, a entidade patronal do Requerente não lhe fixou um prazo certo para apresentar o título de residência, sob pena de ser despedido (…)
Mas mesmo que se verificasse uma situação de urgência qualificada, na acepção do art.º 109º do CPTA, nada impediria o Requerente de requerer a concessão da providência cautelar de intimação da Entidade Requerida a emitir um documento que substituísse provisoriamente o título de residência definitivo até à decisão da causa principal (acção de condenação à prestação de um facto) ou até à efectiva emissão dele.".

Na decisão recorrida entendeu-se, portanto, que o recorrente não provou o requisito relativo à indispensabilidade do presente meio processual - já que, em concreto, nada alegou no sentido de que está em causa a lesão de um direito, liberdade ou garantia cuja protecção carece de emissão urgente de uma decisão de fundo -, salientando-se também que, a verificar-se uma situação de urgência qualificada, na acepção do art. 109º n.º 1, do CPTA, sempre poderia o recorrente solicitar o decretamento de uma providência cautelar.

O recorrente defende que a decisão ora sindicada violou o art. 109º n.º 1, do CPTA, por estar em causa uma situação de especial urgência - porquanto se encontra impossibilitado de ter acesso ao sistema de saúde em igualdade com os demais, a trabalhar e viver do seu trabalho, a viver com tranquilidade, a poder deslocar-se e a rever a sua família ou iniciar o competente processo de reagrupamento familiar -, acrescentando que uma decisão cautelar seria completamente desadequada.

Passemos, então, à análise do acerto (ou não) da decisão judicial recorrida.

Dispõe o art. 109° n.° 1, do CPTA, referindo-se aos pressupostos do pedido de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias, o seguinte:
"A intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias pode ser requerida quando a célere emissão de uma decisão de mérito que imponha à Administração a adopção de uma conduta positiva ou negativa se revele indispensável para assegurar o exercício, em tempo útil, de um direito,

liberdade ou garantia, por não ser possível ou suficiente, nas circunstâncias do caso, o decretamento provisório de uma providência cautelar, segundo o disposto no artigo 131.°".

Desta disposição legal resulta que a utilização deste mecanismo processual depende dos seguintes pressupostos:
1) a necessidade de emissão urgente de uma decisão de mérito seja indispensável para protecção de um direito, liberdade ou garantia;
2) não seja possível ou suficiente o decretamento provisório de uma providência cautelar no âmbito de uma acção administrativa normal.

Conforme explicam Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2005, págs. 538, 539 e 541, em anotação a este normativo legal:
"Os requisitos do n.º 1 são, no entanto, os requisitos mínimos indispensáveis para que se possa lançar mão deste processo de intimação. E são formulados em termos que intencionalmente restringem aquele que, à partida, poderia ser o seu campo de intervenção.
Em primeiro lugar, é necessário que esteja em causa o exercício, em tempo útil, de um direito, liberdade ou garantia e que a adopção da conduta pretendida seja apta a assegurar esse exercício. Mas não basta isto, pois também se exige que a célere emissão da intimação seja indispensável "por não ser possível, nas circunstâncias do caso, o decretamento provisório de uma providência cautelar, segundo o disposto no artigo 131.°".
A imposição deste segundo requisito é da maior importância e deve ser realçada, pois, através dela, o Código assume que, ao contrário do que, à partida, se poderia pensar, o processo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias não é a via normal de reacção a utilizar em situações de lesão ou ameaça de lesão de direitos, liberdades e garantias. A via normal de reacção é a da propositura de uma acção não urgente (acção administrativa comum ou acção administrativa especial), associada à dedução de um pedido de decretamento de providências cautelares, destinadas a assegurar a utilidade da sentença que, a seu tempo, vier a ser proferida no âmbito dessa acção. Só quando, no caso concreto, se verifique que a utilização da via normal não é possível ou suficiente para assegurar o exercício, em tempo útil, do direito, liberdade ou garantia é que deve entrar em cena o processo de intimação.
O processo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias é, assim, instituído como um meio subsidiário de tutela, vocacionado para intervir como uma válvula de segurança do sistema de garantias contenciosas, nas situações – e apenas nessas – em que as outras formas de processo do contencioso administrativo não se revelem aptas a assegurar a protecção efectiva de direitos, liberdades e garantias.
A opção afigura-se compreensível, não parecendo, na verdade, que o âmbito de intervenção desta forma de processo esteja configurado em moldes excessivamente restritivos. Com efeito, cumpre ter presente que o normal e desejável é que os processos se desenrolem nos moldes considerados mais adequados ao cabal esclarecimento das questões, o que exige tempo, o tempo necessário à produção da prova e ao exercício do contraditório entre as partes. Não é, por isso, aconselhável

abusar dos processos urgentes, em que a celeridade é necessariamente obtida através do sacrifício, em maior ou menor grau, de outros valores, que, quando ponderosas razões de urgência não o exijam, não devem ser postergados. Afigura-se, pois, justificado recorrer, por norma, aos processos não urgentes, devidamente complementados por um sistema eficaz de atribuição de providências cautelares, efectivamente apto a evitar a constituição de situações irreversíveis ou a emergência de danos de difícil reparação (sobre os processos cautelares, cfr. artigos 112º e segs.), e reservar os processos urgentes para situações de verdadeira urgência na obtenção de uma decisão sobre o mérito da causa, que são aquelas para as quais, na verdade, não é suficiente a utilização de um processo não urgente, ainda que complementado pelo decretamento – se as circunstâncias o justificarem, provisório (quanto a este ponto, cfr. artigo 131.º) – de providências cautelares.
(…) Cumpre, porém, notar que o sentido do preceito é o de afirmar a existência, (…) de uma relação genérica de subsidiariedade entre este processo e os processos não urgentes (acção administrativa comum e acção administrativa especial). A referência específica ao decretamento provisório de providências cautelares, previsto no artigo 131º, compreende-se, entretanto, porque a relação de subsidiariedade em relação aos processos não urgentes se estende, como não poderia deixar de ser, ao recurso à tutela cautelar – e, dentro desta, à mais incisiva das possibilidades que o regime da tutela cautelar oferece, a do decretamento provisório de providências cautelares, previsto no artigo 131º, quando as circunstâncias o justifiquem.
(…)
Pelo contrário, o processo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias há-de ser chamado a intervir em situações que não possam ser acauteladas deste modo, porque é urgente a obtenção de uma pronúncia definitiva sobre o mérito da causa.
(…)
O que em situações deste tipo é necessário, é obter, em tempo útil e, por isso, com carácter de urgência, uma decisão definitiva sobre a questão de fundo: a questão tem de ser definitivamente decidida de imediato, não se compadecendo com uma definição cautelar. O processo principal urgente de intimação existe precisamente para suprir as insuficiências próprias da tutela cautelar, que resultam do facto de ela ser isso mesmo, cautelar.” (sublinhados e sombreados nossos).

Nesta matéria não podemos também deixar de ter em atenção os ensinamentos colhidos da doutrina expendida por Isabel Celeste M. Fonseca, Dos Novos Processos Urgentes no Contencioso Administrativo (Função e Estrutura), 2004, quando sustenta:
- A págs. 76 e 77, que “Da interpretação e da valoração dos conceitos imprecisos previstos no art. 109.º parece que fica clara a natureza subsidiária da intimação. (…) Ora, a necessidade da intimação urgente, sob a forma de decisão de fundo, afere-se pela impossibilidade ou insuficiência da intimação urgentíssima provisória, sob a forma de decisão cautelar, para assegurar uma protecção eficaz destes direitos.
A indispensabilidade de uma decisão de mérito e a impossibilidade ou insuficiência da medida cautelar urgentíssima provisória constituem, por conseguinte, o centro do conjunto de pressupostos de admissibilidade do processo urgente que cumpre analisar de seguida.
(…)

Quando se pode lançar mão do processo urgente para defesa de direitos, liberdades e garantias?
Em primeiro lugar, como a resposta se pode encontrar por contraste e por oposição das qualidades das categorias de tutela urgente para tutelar direitos, liberdades e garantias, a intimação urgente definitiva tem preferência sobre outros processos comuns (…) e tem primazia na ordem de escolha sobre a intimação urgentíssima provisória, prevista no art. 131º, (…) quando, num caso concreto, em relação às primeiras vias, a intimação urgente definitiva possuir a qualidade do que é absolutamente necessário e, em relação à segunda (à intimação urgentíssima provisória), esta se revelar impossível ou insuficiente.
(…)
A intimação será absolutamente necessária quando não puder ser dispensada, ou seja quando, para proteger direitos fundamentais, a intensidade da necessidade de protecção imediata impeça, por não ser possível em tempo útil, o recurso a um outro meio processual (por exemplo a acção administrativa comum) que seria o meio adequado ou o meio próprio para resolver definitivamente a questão existente." (sublinhados e sombreados nossos);
- A pág. 79, que "Em suma, parece-nos, pois que para solucionar a questão de quais são os pressupostos de admissibilidade do processo urgente a resposta se encontra não pela avaliação de urgências – basta verificar que o processo de intimação poderá estar sujeito a três tipos de tramitação, com três diferentes tipos de andamentos -, mas pelo contraste entre a indispensabilidade de uma decisão de mérito e a apreciação num caso concreto da impossibilidade ou insuficiência de uma qualquer medida cautelar provisória, seja ela a medida cautelar urgentíssima ou outra (normal) cautelar, para assegurar o exercício, em tempo útil, de um direito, liberdade ou garantia.
Sintetizando o já dito: de acordo com a letra da lei, subjacente à necessidade da intimação urgente definitiva existe uma situação de urgência, mas para a qual não servem as vias processuais comuns, porque são lentas demais, nem presta a medida cautelar urgentíssima. E esta não serve por uma razão: porque é uma medida cautelar e, por isso, porque é caracterizada pela provisoriedade. E, não satisfazendo no caso concreto o regulamento provisório, ela deve ser preterida perante o processo urgente que julgue definitivamente o mérito da causa." (sublinhados e sombreado nossos);
- A pág. 82, que "O «dilema» da antecipação assenta, em suma, no factor tempo: o juiz da causa principal não chegaria a tempo de ditar a justiça para a situação e o juiz da causa cautelar se o fizesse teria antecipado ilegitimamente a decisão de mérito." (sublinhados e sombreados nossos);
- A pág. 83, que "E poderíamos dar mais exemplos em que as situações de urgência não admitem espera alguma e, em função disso, se pede ao juiz cautelar que em cumprimento do princípio da tutela jurisdicional «efectiva» antecipe os efeitos do hipotético conteúdo da sentença de mérito. Contudo, nem todas as situações de urgência se satisfazem sem que as decisões antecipatórias ultrapassem os limites da técnica da antecipação. São estas que cumpre identificar caso a caso.
E é sempre no caso concreto, através dum juízo de prognose, que estas se identificam: i) são de natureza improrrogável, que reivindica uma composição jurisdicional inadiável; ii) têm uma natureza que não se compadece com a provisoriedade jurisdicional e que obriga o juiz a pronunciar-se de modo definitivo. Definitivo, no sentido de solução fatal, já que ela matará a utilidade posterior de qualquer sentença de mérito que vier a ser emitida no âmbito de um processo principal que conheça sobre essa situação, de modo mais profundo.";

- A pág. 84, que “Enfim, há situações claras de urgência que são propícias a exigir decisões de fundo. De uma forma generalista, podemos dizer que a situação de urgência pode manifestar-se pela sua configuração em função do tempo: situações sujeitas a um período de tempo curto, ou que digam respeito a direitos que devam ser exercitados num prazo ou em datas fixas – questões conexas com uma eleição, incluindo campanhas eleitorais, situações decorrentes de limitações ao exercício de direitos, num certo dia ou numa data próxima, actos ou comportamentos que devam ser realizados numa data fixa próxima ou num período de tempo determinado, como exames escolares ou uma frequência do ano lectivo. Podem configurar igualmente casos de urgência situações de carência pessoal ou familiar, em que esteja em causa a própria sobrevivência pessoal de alguém. Casos relativos à situação civil ou profissional de uma pessoa podem constituir igualmente uma situação de urgência.” (sublinhados e sombreados nossos);
- E a pág. 85, que “Pegando finalmente no fio à meada… tudo isto para dizer e explicar qual é a lógica subjacente ao conceito de subsidiariedade da intimação para tutela de direitos, liberdades e garantias. Este processo de intimação urgente definitiva permite ao juiz, no domínio de direitos, liberdades e garantias, decidir legitimamente a questão de fundo de modo definitivo, nos casos em que as situações concretas de urgência verdadeiramente o mereçam e o exijam (i).
Para compreender os pressupostos de admissibilidade da intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias, deve partir-se da consideração da absoluta necessidade de emissão de uma decisão de mérito pelo facto de uma medida cautelar se revelar, num certo sentido, como impossível ou insuficiente.(ii).
Já no caso oposto, quando se deva entender que a questão subjacente, ainda que seja relativa a direitos, liberdades e garantias, possa provisoriamente ser composta por via cautelar, esta deve ser a escolha preferida em detrimento da intimação definitiva, podendo actuar cumulativamente com um outro instrumento de tutela principal (iii).
E configurando-se a possibilidade de lesão iminente e irreversível de direitos, liberdades e garantias, a intimação urgentíssima provisória, prevista no art. 131º, constitui a forma especial que tem primazia sobre a utilização do processo cautelar comum. (iv).
Em suma, resultará da análise caso a caso saber quando é que as pronúncias de mérito são necessárias, por contraste com as insuficientes pronúncias cautelares, visto que estas são sempre, na sua globalidade, provisórias, quer sejam emitidas com especial urgência no início do processo cautelar ou não. É na solução deste dilema, nas circunstâncias de cada situação que reside a apreciação da admissibilidade da utilização do processo de intimação para tutela de direitos, liberdades e garantias (v). (…)”.

Do ora exposto decorre que os requisitos de que depende a utilização da intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias – e acima enunciados – reconduzem-se aos seguintes critérios práticos:
1) o juiz do processo (não urgente) principal não chegaria a tempo de ditar a justiça para a situação, isto é, para protecção de um direito, liberdade ou garantia;
2) o juiz da causa cautelar se ditasse a justiça para a situação teria antecipado ilegitimamente a decisão de mérito.

Caracterizados os requisitos ou pressupostos importa frisar que não nos encontramos no domínio da tutela cautelar ou provisória visto que o pedido de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias proporciona uma tutela principal, visando a obtenção pelo autor, em tempo útil e por isso com carácter de urgência, duma pronúncia definitiva sobre a relação jurídico-administrativa em questão, formando-se sobre aquela pretensão/pedido caso julgado material.

Na decisão recorrida afirmou-se, desde logo, que não se verifica no caso vertente o primeiro dos requisitos acima enunciados de que depende a utilização da intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias - indispensabilidade de uma emissão urgente da decisão de mérito -, e com razão, como se passa a demonstrar.

O recorrente afirmou nos articulados apresentados em 1ª instância que o pedido de autorização de residência que formulou, nos termos do art. 88º n.º 2, da Lei 23/2007, de 4/7, foi objecto de acto expresso de deferimento. Em sede de recurso jurisdicional afirma que, caso assim não se entenda, sempre se terá formado um acto tácito de deferimento. Sublinha que tem direito à emissão do título de residência, pois o pedido de autorização de residência já foi objecto de despacho de deferimento.

O recorrente não concretiza, no entanto, qualquer situação da qual resulte a indispensabilidade de que a decisão de mérito seja proferida num processo urgente (e não numa acção administrativa), não dando, por conseguinte, satisfação ao ónus de alegação e de prova que lhe estava cometido, de acordo com as regras gerais do ónus da prova, no sentido de demonstrar a imprescindibilidade do recurso ao presente meio processual e não ser possível em tempo útil o recurso a uma acção administrativa comum.

Com efeito, o recorrente nada alegou – e, portanto, nada provou - no sentido de que, se a decisão de mérito não for proferida num processo urgente, haverá:
- uma perda irreversível de faculdades de exercício do direito em causa (direito a residir (legalmente) em Portugal e a ser portador do respectivo título de residência);
- uma qualquer situação de carência pessoal ou familiar em que esteja em causa a imediata e directa sobrevivência pessoal de alguém (cumpre salientar que o recorrente a este propósito limitou-se a afirmar que tem de pagar na integralidade as taxas para ter aceso ao sistema de saúde e que a sua entidade patronal lhe pede informações sobre o seu processo de regularização em território nacional, concretamente sobre a sua conclusão).

Do exposto decorre que o recorrente não alega um único facto concreto que permita concluir que o invocado direito a residir (legalmente) em Portugal e a ser portador do respectivo título de residência não terá utilidade se for concedido através de decisão a proferir em acção administrativa, isto é, que esta acção não é suficiente para assegurar o exercício em tempo útil desse direito.

Dito por outras palavras, o recorrente não invoca qualquer facto concreto do qual resulte que, pela

circunstância da sua pretensão ser apreciada no âmbito da acção administrativa, ficará sem qualquer utilidade:
- o eventual reconhecimento que venha a ser efectuado nessa acção do alegado despacho de deferimento do pedido de autorização de residência;
- a eventual condenação que aí venha a ocorrer do recorrido a emitir o competente título de residência.

Acresce que o direito ora em causa (direito a residir em Portugal e ao título de residência) não é relativo à situação civil e profissional do recorrente.

Conclui-se, assim, que a questão para a qual é solicitada tutela não pode ser resolvida através do processo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias, visto que não é invocada qualquer situação concreta de urgência a exigir uma decisão de fundo no âmbito desse processo.

Mesmo que, assim, não se entenda, sempre seria de manter a decisão recorrida, já que não se verifica o pressuposto supra enunciado sob o n.º 2) - impossibilidade ou insuficiência do decretamento provisório de uma providência cautelar no âmbito de uma acção administrativa -, dado que é possível e é suficiente o decretamento de uma providência cautelar no âmbito de uma acção administrativa.

Com efeito, o recorrente poderá intentar uma acção administrativa, sendo-lhe possível obter a tutela urgente dos direitos que invoca através de um processo cautelar, no qual formule pedido de intimação do recorrido a emitir, provisoriamente, o título de residência – neste sentido, Carla Amado Gomes Pretexto, contexto e texto da intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias, Março de 2003, pág. 21, in www.icjp.pt/sites/default/files /media/291-135.pdf ["O julgador tem, por isso, que se convencer de que, em face das condições concretas de exercício do direito alegadamente ameaçado, a opção pela tutela sumária é inevitável. Ou seja, e de acordo com o princípio da interferência mínima, sempre que o exercício válido do direito não estiver sujeito a qualquer prazo - leia:se: quando o requerente puder voltar a exercer o direito cuja efectividade está comprometida com um resultado equivalente (descontado o natural decurso do tempo) num momento ulterior -, a tutela cautelar prefere à sumária (57 Por exemplo, e aproveitando parcialmente o exemplo de ISABEL FONSECA (O Código..., cit., loc. cit.), a um estrangeiro destinatário de uma ordem de expulsão que requer a concessão de uma autorização de residência, uma vez obtida a suspensão da eficácia da ordem de expulsão (medida de carácter conservatório), basta-lhe o decretamento provisório da obrigação da Administração na emissão da autorização. O juiz pode assegurar a tutela efectiva do direito sem exceder o limite traçado pelo princípio da interferência mínima.) (sublinhados nossos)"], e Ac. do TCA Sul de 10.11.2011, proc. n.º 8059/11 [em cujo sumário consta o seguinte: "I- A emissão do cartão de equiparado a jornalista, decretada por via do uso de tutela cautelar, não constitui um situação irreversível, podendo ser revogada pelo Tribunal (artigo 124º nº1 do CPTA). II- Assim, não deve ser liminarmente indeferido o pedido de emissão do cartão de equiparado a jornalista, com o argumento da manifesta falta de provisoriedade cautelar"; neste

acórdão explicitou-se que a concessão a título provisório de cartão de equiparado a jornalista (o qual é concedido por dois anos, sujeito a renovação – cfr. art. 9º n.º 2, do DL 70/2008 (1)) não põe em causa a provisoriedade que caracteriza os processos cautelares, acrescentando-se ainda "não ser aplicável o artigo 109º e seguintes do CPTA (intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias), por constituir um meio que é uma última ratio, só aplicável quando não seja suficiente, nas circunstâncias do caso, o decretamento provisório de uma providência cautelar."].

Conclui-se, assim, que, face ao alegado na petição inicial e para tutela dos interesses aí invocados, sempre seria suficiente e adequado o meio processual "normal", ou seja, a acção administrativa, eventualmente acompanhada de um processo cautelar.

Do exposto resulta que a decisão recorrida não violou o disposto no art. 109º n.º 1, do CPTA, ao julgar inidóneo o presente meio processual, razão pela qual deverá ser negado provimento ao presente recurso, mantendo-se a decisão recorrida.

*

Atento o disposto no art. 4º n.ºs 2, al. b), e 6, do Regulamento das Custas Processuais, o recorrente deverá ser condenado nos encargos do presente recurso jurisdicional.

III - DECISÃO

Pelo exposto, acordam, em conferência, os Juízes Desembargadores da Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal Central Administrativo Sul em:

I – Negar provimento ao presente recurso jurisdicional, e, em consequência, manter a decisão recorrida.

II – Condena-se o recorrente nos encargos do presente recurso jurisdicional.

III – Registe e notifique.

*

Lisboa, 15 de Dezembro de 2016

_____

(Catarina Jarmela - relatora)

_____

(Conceição Silvestre)

_____

(Carlos Araújo)

(1)De acordo com o estatuído no art. 75º n.º 1, do DL 23/2007, de 4/7, a autorização de residência temporária é válida pelo período de um ano contado a partir da data da emissão do respectivo título e é renovável por períodos sucessivos de dois anos.

Acórdãos STA

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo

Processo:	0108/17
Data do Acordão:	16/02/2017
Tribunal:	1 SECÇÃO
Relator:	ALBERTO AUGUSTO OLIVEIRA
Descritores:	AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA INTIMAÇÃO MEIO PROCESSUAL APRECIAÇÃO PRELIMINAR REVISTA
Sumário:	Não é de admitir revista se a decisão do acórdão recorrido se apresenta bem sustentada e muito decorrente dos elementos factuais concretos, e a problemática geral trazida ao recurso não revela complexidade ou relevo de importância fundamental.
Nº Convencional:	JSTA000P21506
Nº do Documento:	SA1201702160108
Data de Entrada:	02/02/2017
Recorrente:	A.....
Recorrido 1:	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS
Votação:	UNANIMIDADE
Aditamento:	

Texto Integral

Texto Integral:

Acordam na Formação de Apreciação Preliminar da Secção de Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. A……., de nacionalidade paquistanesa, intentou intimação contra o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), pedido a sua condenação a emitir título de autorização de residência.

1.2. O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, por sentença de 26.9.2016, julgou procedente a acção.

1.3. Em recurso, o Tribunal Central Administrativo Sul, por acórdão de 15.12.2016, revogou a sentença «pois que as circunstâncias do caso não são de molde a justificar o decretamento de uma intimação, por se bastarem com a adopção de uma providência cautelar, pelo que, assim, incorreu em erro de julgamento nessa apreciação. Para o que devem os autos baixar a fim de ser proferido despacho nos termos e para os efeitos do disposto no art. 110.º-A, n.º 1, do CPTA».

1.4. É desse acórdão que o Autor vem, ao abrigo do artigo 150.º do CPTA, interpor recurso de revista.

1.5. O Demandado sustenta a não admissão.

Cumpre apreciar e decidir.

2.1. Tem-se em atenção a factualidade considerada no acórdão recorrido.

2.2. O artigo 150.º, n.º 1, do CPTA prevê que das decisões

proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo possa haver, «excepcionalmente», recurso de revista para o Supremo Tribunal Administrativo «quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental» ou «quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito».
A jurisprudência deste STA, interpretando o comando legal, tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso, referindo que o mesmo só pode ser admitido nos estritos limites fixados neste preceito. Trata-se, efectivamente, não de um recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei nºs 92/VIII e 93/VIII, de uma «válvula de segurança do sistema» que apenas deve ser accionada naqueles precisos termos.

2.3. Como decorre da introdução, o acórdão recorrido julgou que a intimação não é o meio processual adequado para as circunstâncias do caso.
As considerações do acórdão no que respeita à figura da intimação para a protecção de direitos liberdades e garantias encontra-se sustentada em variada doutrina e jurisprudência.
Já no que respeita ao presente pedido disse o acórdão, a certo passo: «No caso em apreço, o ponto da discussão não está na qualificação do direito invocado como direito fundamental – o que tendencialmente se aceita – está sim na existência de uma situação de urgência, sua exigência e respectiva qualificação adjectiva».
E depois: «Na verdade, aceitando embora que foi concretizada na p.i., e reconhecida na decisão recorrida, a existência de uma situação jurídica susceptível de colidir com um direito, liberdade e garantia de natureza pessoal; importava também a mesma concretização quanto ao requisito da ocorrência de uma situação, no caso concreto, de grave ameaça ou violação do direito, liberdade e garantia em causa, que só pudesse – possa – ser reparada através do processo urgente de intimação».
Mais à frente: «limitou-se a alegar generalidades, nada de concreto vindo alegado que permita sustentar uma especial urgência na tomada de decisão judicial. Aliás, a sentença recorrida, a este respeito, apenas deu como provado que: “4- A falta de decisão sobre o pedido do A. e seus familiares causa-lhes prejuízos.” Nada mais ficou nesta sede demonstrado e certamente a existência de “prejuízos”, por si só, não impõe a intimação».

Portanto, a decisão foi baseada na verificação dos elementos aportados aos autos, não em função de uma genérica consideração de que pretensão de autorização de residência, como pretensão tipo, esteja necessariamente afastada do meio processual intimação.

O recorrente intenta, entre o mais, a violação do «Princípio da Equiparação ou do Tratamento Nacional, previsto no artigo 15.º, n.º 1, da CRP, bem com assim, todos os demais direitos, liberdades e garantias, e

direitos fundamentais de natureza análoga aí decorrentes» (conclusão B)

Afigura-se que será ir longe de mais retirar da canalização do interessado para outro meio processual, que não o utilizado, aquele conjunto de violações. Seria como afirmar que se o CPTA não contivesse especificamente esse meio, nos exactos termos em que se encontra configurado, ficavam inevitavelmente violados aqueles princípios e direitos. E não poderá ser assim, atenta a margem de conformação do legislador na definição dos meios. Aliás, nessa margem de conformação o CPTA, na versão de 2015, veio precisamente aditar o artigo 110.º-A, que é aquele que o acórdão manda cumprir. Mas da inexistência desse preceito não resultava que antes houvesse alguma violação do dever de protecção.
Na circunstância, como se viu, o tribunal teve em conta os termos do carreado para os autos.
Trata-se, nessa medida, de situação particular que só requereria a intervenção deste Supremo, em revista excecional, se se observassem a violações alegadas. Ora, no quadro do discutido tudo leva a crer que o meio indicado pelo acórdão é capaz de satisfazer os interesses em jogo.
E o demais alegado não constitui problemática capaz de integrar os requisitos de admissão da revista.

3. Pelo exposto, não se admite a revista.
Sem custas.
Lisboa, 16 de Fevereiro de 2017. – Alberto Augusto Oliveira (relator) – Costa Reis – São Pedro.